**Geschäftsnummer:**
7 O 100/10

Verkündet am
18. Februar 2011

Klein, JSin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

# Landgericht Mannheim

7. Zivilkammer

# Im Namen des Volkes

# Urteil

Im Rechtsstreit

**IPCom GmbH & Co. KG**
vertreten durch d. Komplementär GmbH, diese vertr. d. d. Geschäftsführer Bernhard Frohwitter und Christoph Schoeller
Zugspitzstraße 15, 82049 Pullach

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte HengelerMueller u. Koll., Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf (3631183_1)

**gegen**

1. **Nokia Corporation**
   vertreten durch d. Vorstand, dieser vertr. durch den Vorstandsvorsitzenden Olli-Pekka Kallasvuo
   Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland
2. **Nokia GmbH**
   vertreten durch d. Geschäftsführer Michael Bültmann, Klaus Goll und Heikki Tarvainen
   Rensingstraße 15, 44807 Bochum

   - Beklagte -

   Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
   Rechtsanwälte Bird & Bird u. Koll., Karl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf

**Streithelferin:**

**Telekom Deutschland GmbH**
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Reimann u. Koll., Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf

**wegen** Patentverletzung

hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom 03. Dezember 2010 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Voß
Vors. Richterin am Landgericht Rudolph
Richter am Landgericht Dr. Tochtermann

für **Recht** erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-- - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

   im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patentes EP 1 841 268

   Mobilstationen zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz, in dem mehrere Nutzerklassen unterschieden werden, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   wobei die Mobilstationen dazu eingerichtet sind, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, über einen Broadcast Control Channel Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen zu empfangen, aus den Zugriffsschwellwertbits einen Zugriffsschwellwert zu ermitteln, anhand der für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformationen zu ermitteln, ob die Mobilstation unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien Zugriffskanal (RACH) zugreifen darf, oder ob die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal (RACH) in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 3. November 2007 begangen haben und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie für die Zeit seit dem 01.09.2008 der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und - preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,

wobei von den Beklagten die Angaben zu e) erst seit dem 17. April 2010 zu machen sind,

und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkretes Befragen mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse, die sich im Besitz Dritter befinden, die nicht Endabnehmer sind, aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen;

4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen oder aufgrund der unter 3. oder 4. geltend gemachten Ansprüche in ihren Besitz gelangten und gelangenden, unter 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin für die in Ziffer I.1. bezeichneten, in der Zeit vom 3. November 2007 bis zum 17. April 2010 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen ab dem 18. April 2010 entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Widerklage und Hilfswiderklage werden abgewiesen.

V. Die Nebenintervenientin wird zugelassen.

VI. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten 1/10 als Gesamtschuldner sowie jede der Beklagten für sich je weitere 9/20. Die Kosten der Nebenintervention fallen der Streithelferin zur Last.

VII. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 30.000.000,-- in Ziffer I.1. (Unterlassung), € 100.000,-- in Ziffer I.2. (Rechnungslegung), jeweils € 10.000.000,-- in Ziffer I.3 (Rückruf/Entfernung) und Ziffer I.4. (Vernichtung) und 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer V (Kosten).

# Tatbestand

Die Parteien streiten über Unterlassungs-, Auskunfts-, Rechnungslegungs-, Rückruf-, Entschädigungs-, Vernichtungs- und Schadensersatzpflichten ebenso wie um die Verpflichtung, patentverletzende Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zu entfernen und die Befugnis der Klägerin, das von ihr begehrte Urteil zu veröffentlichen.

Das dem hiesigen Rechtsstreit zugrundeliegende Patent EP 1 841 268 (im Folgenden: Klagepatent, Anlage B7) wurde durch Schriftsatz vom 04.02.2010, bei Gericht eingegangen am 05.02.2010, im Wege der Klageerweiterung in dem durch Beschluss der Kammer vom 18.12.2009 ausgesetzten Rechtsstreit betreffend die Verletzung des deutschen Teils des Patents EP 1 186 189, Az.: 7 O 182/08, geltend gemacht. Dem Schriftsatz lag ein Verrechnungsscheck über € 22.368,- bei, der vorläufige Streitwert wurde mit € 2.000.000,-- angegeben. Der Betrag von € 22.368,- wurde am 09.02.2010 bei der Landesoberkasse Baden-Württemberg eingezahlt und am 15.02.2010 dort gebucht. Die Klageerweiterung wurde den Beklagten aufgrund der Verfügung des Vorsitzenden vom 08.02.2010 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 18.02.2010 erklärten sich die Beklagten mit der von der Kammer vorgeschlagenen Prozesstrennung hinsichtlich der mit der Klageerweiterung vom 04.02.2010 erhobenen Ansprüche einverstanden.

Die Beklagten erhoben mit Schriftsatz vom 26.02.2010 (vgl. Anlage K 72 zum Verfahren 7 O 182/08 mit dt. Übersetzung, dort S.12) vor dem Tribunale di Milano in Italien eine negative Feststellungsklage, die auf Feststellung der Nichtverletzung „des italienischen und deutschen Teils der am 15. Februar 2000 angemeldeten europäischen Patentanmeldung oder - sofern dies im Verlauf der vorliegenden Verhandlungen erteilt wird - des Europäischen Patents Nr. 1 841 268“ durch die Mobiltelefone Nokia 5800 Xpress Music und Nokia N 96 oder andere nach dem UMTS Standard arbeitende Telefone von Nokia gerichtet war. Die Klage ist am 10.03.2010 beim Tribunale di Milano eingegangen (vgl. Stempel Anlage B 5b in Anlagenband II C).

Das Klagepatent betrifft den Zugriff einer Mobilstation auf einen wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse und nimmt eine Unionspriorität vom 08.03.1999 in Anspruch. Die Bundesrepublik Deutschland ist als Vertragsstaat benannt, die Erteilung

des am 15.02.2000 angemeldeten Patents wurde am 17.03.2010 veröffentlicht, wobei die Anmeldung am 03.10.2007 veröffentlicht worden war.

Gegen den deutschen Teil des in Kraft stehenden Klagepatents haben die Beklagte zu 1 (Anlagenkonvolut B 9), die HTC Corporation (Anlage B 116), die Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Anlage B 116a) und die Telekom Deutschland GmbH (Anlage ROKH 1) Einspruch eingelegt.

Der geltend gemachte Anspruch 1 hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

Mobilstation (5, 10, 15, 20) zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz, in dem mehrere Nutzerklassen (35, 40) unterschieden werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Mobilstation (5, 10, 15, 20) dazu eingerichtet ist,

- eine Nutzerklasse (35, 40) von einer SIM-Karte (75) zu lesen,
- über einen Broadcast Control Channel (25) Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) und Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu empfangen
- aus den Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) einen Zugriffsschwellwert (S) zu ermitteln,
- anhand der für die Nutzerklasse (35, 40) relevanten Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu ermitteln, ob die Mobilstation (5, 10, 15, 20) unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) auf einen wahlfreien Zugriffskanal, zum Beispiel RACH, zugreifen darf,
  oder ob die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal zum Beispiel RACH, in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird.

Hinsichtlich des weiteren Inhalts, insbesondere der Patentbeschreibung, wird auf die Klagepatentschrift (Anlage B 7) verwiesen.

Die Klägerin, eine Patentverwertungsgesellschaft, ist originäre und eingetragene Inhaberin des Klagepatents.

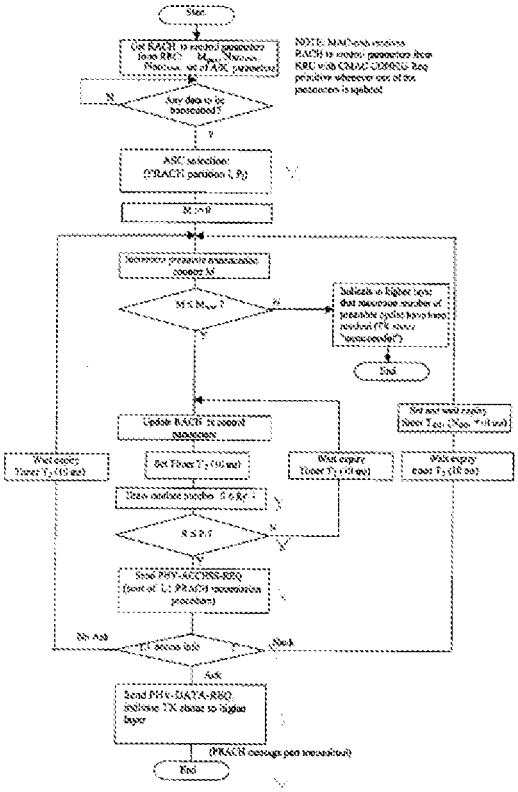
Sie erwarb im Mai 2007 ein umfangreiches Patentportfolio von der Robert Bosch GmbH. Zu dem Patentportfolio zählte auch das europäische Patent EP 1 186 189, wobei die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung 07009265.5 eine Teilanmeldung zu der Anmeldung 00916749.5 ist, aus der der Robert Bosch GmbH das europäische Patent 1 186 189 erteilt worden war. Dieses Stammpatent wurde im Zuge des Portfolioerwerbs von der Robert Bosch GmbH auf die Klägerin übertragen.

Die Beklagte Ziffer 1, eine Mobilfunkgeräteherstellerin mit Sitz in Finnland, vertreibt bundesweit und insbesondere durch ihre in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Tochtergesellschaft, die Beklagte Ziffer 2, Mobilfunkgeräte, hierunter die Modelle Nokia 5800 XpressMusic und Nokia N96, die UMTS-fähig sind.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) beruht auf Mobilfunkstandards des 3rd-Generation-Partnership-Projects (3GPP), die in einzelnen Dokumenten des European Telecommunications Standards Institute (ETSI) niedergelegt sind.

Im standardrelevanten Dokument mit der Bezeichnung ETSI TS 125 321, Version 6.14.0 (Anlage K 9) wird in Abschnitt 11.2 (*Control of RACH Transmissions*) ein Zugriffskontrollverfahren auf den wahlfreien Zugriffskanal RACH (*Random Access Channel*) beschrieben, über den Mobilstationen auf Dienste des Netzwerks zugreifen. Die physikalischen Ressourcen des RACH können zwischen verschiedenen „*Access Service Classes*“ (ASC) aufgeteilt werden, um so verschiedene Nutzungsprioritäten einzuräumen (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 1. Abs.). Zu diesem Zweck sind im Standard acht *Access Service Classes* von ASC#0 bis ASC#7 vorgesehen, wobei ASC#0 die höchste Zugriffspriorität aufweist, ASC#7 die niedrigste (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 2. Abs.).

Der Zugriff der jeweiligen Mobilstation auf den RACH hängt nach dem in Figur 11.2.2.1 grafisch dargestellten Verfahrensablauf von einem Vergleich eines in der Mobilstation berechneten und unter Umständen (vgl. Anlage K 10, TS 125.331, Abschnitt 8.5.12, 5. Absatz: “*Scaling factors $s_i$ are provided* <u>*optionally*</u>...“ [Hervorhebung diesseits]) skalierten Persistenzwertes $P_i$ mit einer in der Mobilstation generierten Zufallszahl R ($0 \leq R < 1$) ab, wobei die Verbindlichkeit des in der Figur dargestellten Verfahrensablaufs zwischen den Parteien in Streit steht. Entsprechend der Figur ist der Zugriff der Mobilstation auf den RACH frei, wenn die generierte Zufallszahl $R \leq P_i$ ist:



Sobald die Mobilstation ihren Zugriffswunsch (*RRC Connection Request*) über den RACH an die Basisstation senden will, muss sie zunächst ermitteln, welche ASC ihr zugewiesen ist. Diese Bestimmung erfolgt über die der jeweiligen Mobilstation zugewiesene *„Access Class“* (AC) (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 5. Abs.: *„When an RRC CONNECTION REQUEST message is sent RRC determines ASC by means of the access class [7].“*) Die Referenz „[7]“ verweist gemäß Abschnitt 2 (*References*) des Standards ETSI 125 321 auf das Dokument 3GPP TS 125.331: *„Radio Resource Control (RRC); protocol specification“* (Anlage K 10).

In dessen Abschnitten 8.5.12 und 8.5.13 wird die Beziehung zwischen *Access Class* (AC) und *Access Service Class* (ASC) näher beschrieben. Die Zuordnung der Mobilstation zu einer bestimmten ASC erfolgt entsprechend der auf der SIM-Karte festgelegten (vgl. Anlage K 11, ETSI TS 122 011, Abschnitt 4.2: *„All UEs are members of one out of ten randomly allocated mobile populations, defined as Access Classes 0 to 9. The population number is stored in the SIM/USIM.“*) Access Class (AC), nach dem von der Basisstation übermittelten Informationselement *„Mapping of Access Classes to Access Service Classes“* (*„AC to ASC Mapping“*, Anlage K 10, ETSI TS 125 331, Version 6.16.0, Abschnitt 8.5.13):

| **AC** | **0 - 9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASC** | 1st IE | 2nd IE | 3rd IE | 4th IE | 5th IE | 6th IE | 7th IE |

Der für die Zugriffsentscheidung maßgebliche Persistenzwert $P_i$ wiederum ergibt sich gemäß nachstehender Tabelle in Abhängigkeit von der der Mobilstation jeweils zugeordneten ASC (Anlage K 10, ETSI TS 125.331, Abschnitt 8.5.12):

| ASC # *i* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_i$ | 1 | P(N) | $s_2$ P(N) | $s_3$ P(N) | $s_4$ P(N) | $s_5$ P(N) | $s_6$ P(N) | $s_7$ P(N) |

Mit Ausnahme der ASC#0, der immer ein Zugriff möglich ist, weil ihr feststehend der Persistenzwert $P_i = 1$ zugewiesen ist und der Wert damit immer größer oder gleich R ist und ein Zugriff erfolgen kann, bestimmt sich für die übrigen ASC der Persistenzwert $P_i$ in Abhängigkeit vom dynamischen Persistenzniveau N (*„dynamic persistence level N = 1, …, 8“*) nach der feststehenden Beziehung $P(N) = 2^{-(n-1)}$, wobei gegebenenfalls in die Berechnung der Skalierungsfaktor $s_i$ einfließt. Das dynamische Persistenzniveau N wird von der Basisstation bestimmt und an alle Mobilstationen im *System Information Block*

*(SIB) type 7* permanent übertragen (ETSI TS 125 331, 8.5.12, Anlage K 10), während die Skalierungsfaktoren und das Informationselement „AC to ASC mapping“ im *SIB type 5* oder *5bis* übertragen werden (ETSI TS 125 331, 8.5.13, Anlage K 10).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die zitierten Standarddokumente verwiesen.

Die vormalige Inhaberin des Stammpatents EP 1 186 189, die Robert Bosch GmbH, gab als Mitglied im Hinblick auf die interessierenden Standards auf der Grundlage der „*General IPR Licensing Declaration*“ gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung ab, wonach jedem interessierten Hersteller zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen an den als standardessentiell angegebenen Patenten Lizenz erteilt werde.

Die Beklagten gaben in einem vor dem Landgericht Düsseldorf geführten Verfahren ein Lizenzangebot ab (Anlage B 55), wobei die Parteien darüber streiten, ob das im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte Klagepatent hierdurch erfasst ist, und zahlten einen Betrag von € 35.000.000,-- auf einem Treuhandkonto der Nordea Bank Finland plc ein (Anlagen B 66-68).

In Betracht des der Streithelferin durch die Beklagten (AS 606 ff.) verkündeten Streits ist die Streithelferin auf Seiten der Beklagten dem Rechtsstreit mit Anwaltsschriftsatz vom 02.12.2010 (AS 770 ff.) beigetreten.

Die Klägerin ist der Auffassung,
die Kammer sei zur Entscheidung auch über die geltend gemachten Entschädigungsansprüche berufen. Die in Italien erhobene negative Feststellungsklage entfalte keine Sperrwirkung gegenüber der zeitlich zuvor vor dem Landgericht Mannheim erhobenen Klage. Die Geltendmachung des Klagepatents im Wege der Klageerweiterung im ausgesetzten Verfahren 7 O 182/08 sei nicht nur zulässig, sondern wegen § 145 PatG geboten gewesen. § 249 Abs. 2 ZPO hindere die Wirksamkeit der Klageerweiterung nicht, zudem sei ein etwaiger Fehler nach § 295 ZPO geheilt, weil die Beklagten der von der Kammer vorgeschlagenen Prozesstrennung hinsichtlich der mit der Klageerweiterung erhobenen Ansprüche ausdrücklich zugestimmt hätten.

Die durch die Beklagten hergestellten und vertriebenen UMTS-fähigen Mobilfunkgeräte seien dazu geeignet und bestimmt, die durch das Klagepatent gelehrte Erfindung zu benutzen. Mangels Berechtigung verletzten die Beklagten Anspruch 1 des Klagepatents, weil die standardgemäß arbeitenden Mobilfunkgeräte sämtliche Merkmale des Anspruchs wortsinngemäß verwirklichten.
Die Mobiltelefone Nokia 5800 XpressMusic und Nokia N96 sowie sämtliche sonstigen UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten seien Mobilstationen zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz im Sinne des Merkmals 1. Da es sich bei Anspruch 1 um einen Vorrichtungsanspruch handele, komme es nur auf die Ermittlung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung der beanspruchten Vorrichtung an. Dem Fachmann sei klar, dass die Aufnahme des UMTS-Standards in den Wortlaut des Merkmals 1 nur insoweit relevant sei, als hierdurch mittelbar bestimmte Anforderungen an den geschützten Gegenstand definiert würden. Der Fachmann erkenne, dass vom Anspruch nicht lediglich Mobilstationen erfasst würden, die zum Betrieb in dem zum Prioritätszeitpunkt existenten UMTS-Standard geeignet seien. Erfasst würden vielmehr auch alle Mobilstationen, die in dem zum Schluss der mündlichen Verhandlung geltenden Standard arbeiten könnten. Entscheidend sei nur, dass die erfinderische Lehre im UMTS-Standard aufgenommen sei. Dem Fachmann sei bewusst, dass UMTS als Netzwerkstandard mit der Zeit fortgeschrieben würde, weshalb der Versuch der Beklagten untauglich sei, das Merkmal einzig auf den Release 1999 Standard einzuschränken, um so die Verletzungsfrage dadurch verneinen zu können, dass die Mobilstationen nicht rückwärtskompatibel seien.

Nach dem UMTS-Standard seien 15 verschiedene Nutzerklassen vorgesehen, die jeweils auf der SIM-Karte der Mobilstation gespeichert seien, wobei es sich hierbei wiederum um kein Element der geschützten Vorrichtung handele. Daher sei auch Merkmal 1a verwirklicht.

Die Mobilstationen der Beklagten seien auch dazu in der Lage, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen. Daher sei Merkmal 2a wortsinngemäß verwirklicht. Da der Wortlaut nur verlange, dass die Mobilstation „dazu eingerichtet“ sein müsse, diese Funktionalität zu erfüllen, ginge die Argumentation der Beklagten, sie vertrieben keine SIM-Karten, an der Sache vorbei. Ebenso wenig sei der Anspruch darauf reduziert, dass allein die im Prioritätszeitpunkt existenten SIM-Karten in den Blick genommen würden.

Merkmal 2b sei ebenfalls wortsinngemäß erfüllt. Das dynamische Persistenzniveau N entspreche den patentgemäßen Zugriffsschwellwertbits, die Tabelle „*AC to ASC-Mapping*“ stelle die Zugriffsklasseninformation dar. Über die Formel $P(N) = 2^{-(n-1)}$ werde aus N der für eine Zugriffsschwellwertauswertung verwendete Zugriffsschwellwert P(N) ermittelt, der in UMTS für die ASC#1 bis ASC#7 über einen Vergleich mit einer Zufallszahl über den Zugriff auf den RACH entscheide. Dass P(N) selbst nicht binär kodiert übertragen, sondern erst aus N berechnet werde, sei für die Verwirklichung des Merkmals irrelevant. Weder sei der Anspruch auf das 13-Bitbeispiel beschränkt noch müssten Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen zeitgleich im selben Datenstrom übertragen werden. Entscheidend sei allein, dass der Mobilstation die Informationen im Zeitpunkt des Zugriffswunschs auf den RACH zur Verfügung stünden.

Nach dem Standard würde auch aus den übertragenen Zugriffsschwellwertbits ein Zugriffsschwellwert nach Merkmal 2c des Klagepatents ermittelt. Aus dem Parameter N werde in UMTS für die Zugriffsklassen ASC#1 bis 7 über die Formel $P(N)=2^{-(N-1)}$ ein Wert $P_i=P(N)$ errechnet, der mit Zufallszahl verglichen werde, wobei der Ausgang des Vergleichs über Zugriff auf RACH entscheide. $P_i= P(N)$ sei damit der Zugriffsschwellwert (S) der aus den Zugriffsschwellwertbits - dem binär codierten Persistenzniveau N - ermittelt werde. Der Verwirklichung des Merkmals stehe nicht entgegen, dass P(N) nicht selbst binär kodiert übertragen werde, sondern nur N, aus dem sich P(N) nach den Festlegungen im Standard bestimme. Jedes UMTS-fähige Handy müsse in der Lage sein, den Zugriffsschwellwert über die standardgemäß vorgegeben Formel für P(N) zu berechnen. Dass unter Umständen Skalenfaktoren in die Berechnung einflössen, sei wiederum ohne Belang, weil sie zum einen nur optional seien und zum anderen für die ASC#0 und ASC#1 ohnehin nicht skaliert werde. Der Wortlaut erfordere zudem nicht, dass der Zugriffsschwellwert S ausschließlich aus den Zugriffsschwellwertbits ermittelt werden müsse. Das von den Beklagten angeführte „Egalitätsprinzip“ sei allein deren Postulat, lasse sich indes aus der Patentschrift nicht ableiten. Selbst bei Zugrundelegung dieser verfehlten Auffassung sei es darüber hinaus für die ASC#0 oder ASC#1 erfüllt.

Schließlich werde auch die Merkmalsgruppe 2d verwirklicht. Denn bei allen nach dem UMTS-Standard arbeitenden Mobiltelefonen werde anhand der für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformationen ermittelt, ob die Mobilstation unabhängig von den

empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien Zugriffskanal zugreifen dürfe oder ob die Zugriffsberechtigung in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt werde. Denn jedes UMTS-fähige Handy der Beklagten erhalte über den Parameter „*AC to ASC Mapping*“ die Information, welche ASC der aus der SIM-Card ausgelesenen AC zugewiesen sei. Wenn dies die ASC#0 sei, so dürfe die betreffende Mobilstation unabhängig von einer Auswertung des dynamischen Persistenzniveaus N auf den RACH zugreifen, weil der Persistenzwert $P_i$ in diesem Fall auf 1 gesetzt sei und der Zugriff damit nicht mehr von der Zugriffsschwellwertbestimmung abhänge. Aufgrund der Beziehung $0 \leq R < 1$ sei für diesen Fall immer ein Zugriff möglich, da der Wert bei der patentgemäßen Lotterie, bei der der Wert $P_i$ mit der Zufallszahl R nach $R \leq P_i$ verglichen werde, immer gewinne und damit der Zugriff erlaubt sei. R sei dann nämlich immer kleiner oder gleich $P_i$. Entscheidend sei, dass für diesen Fall die Ermittlung der Zugriffsberechtigung unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits sei. Dass nach dem UMTS gleichsam ein „Vergleich im Leerlauf“ stattfinde, dessen positives Ergebnis indes immer schon von vornherein feststehe, sei nicht schädlich. Auch dann werde im Sinne des Wortlauts „unabhängig“ von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits anhand der für die Nutzerklassen relevanten Zugriffsklasseninformationen ermittelt, ob ein Zugriff auf RACH erfolgen dürfe. Der Wortlaut „unabhängig von“ könne nicht - wie die Beklagten es versuchten - im Sinne einer Nichtauswertung interpretiert werden. Das Patent lasse vielmehr offen, auf welche Weise sichergestellt werde, dass der Parameter keinen Einfluss auf die Zugriffsentscheidung habe. Bei ASC#1 bis 7, dort bei ASC#2-7 ggf. skaliert, finde hingegen das Lotterieverfahren so statt, wie es Merkmal 2 d (ii) vorsehe.
Das entsprechende Verfahren lasse sich aus dem verbindlichen Standard ETSI 125 321, dort Figur 11.2.2.1, ebenso ableiten wie aus den übrigen standardrelevanten Dokumenten ETSI TS 125 331, Abschnitte 8.5.12 und 8.5.13 sowie ETSI TS 125 321 Abschnitt 11.2.2. Ob es daneben noch den von den Beklagten angeführten, weiteren Zugriffsmechanismus „*Access Class Barred*“ gebe, sei für die Frage der Patentverletzung unerheblich.

Die erfinderische Lehre sei hinreichend erfinderisch gegenüber den Dokumenten GSM 138 und GSM 04.60, wobei die fehlende Neuheitsschädlichkeit derselben zwischen den Parteien außer Streit stehe. Auch liege weder eine unzulässige Erweiterung

vor noch habe die Klägerin das Klagepatent erschlichen, weshalb eine Aussetzung des Rechtstreits nicht in Betracht komme.

Einen Lizenzeinwand könnten die Beklagten der Klägerin nicht entgegenhalten. In ihrer Argumentation übersähen die Beklagten den Umstand, dass die Klägerin originäre Inhaberin des Klagepatents sei und die rechtlichen Verbindungen der Klägerin zur Robert Bosch GmbH damit vorliegend ohne Belang seien. Wie die Kammer zutreffend in anderen Verfahren entschieden habe, finde französisches Recht auf die Frage eines etwaigen Nutzungsrechts aufgrund einer ETSI-Lizenzbereitschaftserklärung keine Anwendung. Dies folge neben den Erwägungen der Kammer bereits aus dem Schutzlandprinzip, das zur Anwendung deutschen Rechts führe. Danach stehe den Beklagten jedoch kein Nutzungsrecht zu. Selbst bei Zugrundelegung französischen Rechts könnten sich die Beklagten auf kein Nutzungsrecht berufen.

Sofern die Beklagten der Inanspruchnahme wegen Patentverletzung den dolo-agit- Einwand entgegenhalten wollten, erfüllten sie schon nicht die „Orange-Book"-Kriterien, die der Bundesgerichtshof aufgestellt habe.

Die Widerklage sei abzuweisen, da die Widerklägerin keinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages auf Basis der von ihr vorgelegten Anlage B 55 habe. Die Widerklägerin habe bisher weder ordnungsgemäß Rechnung gelegt noch die erforderliche Lizenzgebühr gezahlt oder hinterlegt. Der Hilfsantrag sei wegen des Vorrangs der Leistungsklage bereits unzulässig. Soweit die Relevanz der Anlage B 53 festgestellt werden solle, fehle es an einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis.

Die Klägerin **b e a n t r a g t**:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-- - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

   im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patentes EP 1 841 268

Mobilstationen zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz, in dem mehrere Nutzerklassen unterschieden werden, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wobei die Mobilstationen dazu eingerichtet sind, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, über einen Broadcast Control Channel Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen zu empfangen, aus den Zugriffsschwellwertbits einen Zugriffsschwellwert zu ermitteln, anhand der für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformationen zu ermitteln, ob die Mobilstation unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien Zugriffskanal (RACH) zugreifen darf, oder ob die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal (RACH) in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 3. November 2007 begangen haben und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und - preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,

wobei von den Beklagten die Angaben zu e) erst seit dem 17. April 2010 zu machen sind,

und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkretes Befragen mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

3. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindli-

chen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie die notwendigen Verpackungs- und Lagerkosten zu übernehmen;

4. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei die Erzeugnisse vom jeweiligen gewerblichen Abnehmer

a) zu vernichten oder nach Wahl der Klägerin an einen von ihm zu benennenden Treuhänder zum Zweck der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben oder

b) an die Beklagten zurückzugeben sind;

5. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen oder aufgrund der unter 3. oder 4. geltend gemachten Ansprüche in ihren Besitz gelangten und gelangenden, unter 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben;

6. der Klägerin zu gestatten, Urteilskopf, Urteilstenor und Auszüge aus den Entscheidungsgründen durch eine in drei aufeinander folgenden Ausgaben der Zeitung „Handelsblatt“ erscheinende halbseitige Anzeige öffentlich bekannt zu machen.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin für die in Ziffer I.1. bezeichneten, in der Zeit vom 3. November 2007 bis zum 17. April 2010 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen ab dem 18. April 2010 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten **b e a n t r a g e n:**

die Klage abzuweisen;

hilfsweise: den Beklagten im Falle einer Verurteilung gemäß den Klageanträgen zu gestatten, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden (§ 712 ZPO),

weiter hilfsweise: der Klägerin die Vollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 100 Millionen zu gestatten.

zudem hilfsweise: 1. den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen den Rechtsbestand des Klagepatents beim Europäischen Patentamt erhobenen Einspruch auszusetzen.

2. den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim OLG Karlsruhe anhängigen Berufungsverfahren 6 U 66/09 (zum Urteil des Landgerichts Mannheim im Verfahren 2 O 1/07) auszusetzen.

das Verfahren analog § 148 ZPO auszusetzen und dem Gerichthof der Europäischen Union folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Art. 101 AEUV dahin auszulegen, dass auf Verpflichtungserklärungen, die gemäß Art.6.1 der ETSI IPR Policy abgegeben werden, nach Maßgabe von Art.12 der ETSI IPR Policy einheitlich und unabhängig vom Schutzland des zugrundeliegenden Schutzrechts sowie vom Sitz des Schutzrechtsinhabers und des Nutzers des betreffenden Standards französisches Recht anzuwenden ist?

Die Beklagte zu 1 **b e a n t r a g t** im Wege der **Widerklage**:

1. die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, das als Anlage B 55 ausformulierte Vertragsangebot der Beklagten zu 1 und Widerklägerin auf Abschluss eines Lizenzvertrages an dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 186 189, dem deutschen Gebrauchsmuster DE 200 24 006.4 und dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 841 268 anzunehmen;

hilfsweise,

2. festzustellen, dass die Klägerin und Widerbeklagte verpflichtet ist, der Beklagten zu 1) und Widerklägerin eine Lizenz an dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 186 189, dem deutschen Gebrauchsmuster DE 200 24 006.4 und dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 841 268 zu Bedingungen zu erteilen, die im wesentlichen vergleichbar sind mit den Bedingungen, die in dem ausformulierten Lizenzangebot gemäß Anlage B 55 enthalten sind.

weiter beantragen die Beklagten im Wege der Widerklage

festzustellen, dass der als Anlage B 53 vorgelegte Auszug für dieses Verfahren relevant ist.

Die Streithelferin **b e a n t r a g t**,

sie als Nebenintervenientin zuzulassen,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise: den Rechtsstreit auszusetzen.

Die Klägerin tritt den Aussetzungsanträgen entgegen, beantragt Abweisung der widerklageweise geltend gemachten Ansprüche und rügt den Beitritt der Streithelferin als unzulässig.

Die Beklagten sind der Auffassung,
die Kammer sei hinsichtlich der geltend gemachten Entschädigungsansprüche örtlich unzuständig. Überdies sei das Verfahren nach Art. 27 EuGVVO auszusetzen, weil zuvor negative Feststellungsklage vor dem Tribunale di Milano erhoben worden sei. Die Klägerin habe das neue Klagepatent nicht im Wege der Klageerweiterung im ausgesetzten Verfahren 7 O 182/08 geltend machen können.

Die angegriffenen Ausführungsformen machten vom Wortlaut des Anspruchs 1 ohnehin keinen Gebrauch, weil der UMTS-Standard, anhand dessen die Verletzungsfrage von der Klägerin dargelegt würde, nicht von den Merkmalen der erfinderischen Lehre Gebrauch mache. So seien die von den Beklagten hergestellten und vertriebenen Mobiltelefone nicht fähig, in dem zum Prioritätszeitpunkt aktuellen UMTS Standard Release 1999 zu arbeiten, weshalb Merkmal 1 nicht verwirklicht sei.
Im innerhalb der Bundesrepublik Deutschland betriebenen UMTS-Netz würden auch keine mehreren Nutzerklassen unterschieden, wie es Merkmal 1a verlange. So würden in dem durch die Streithelferin betriebenen Netz alle Mobilstationen auf die Nutzerklasse 0 gemappt. Damit unterscheide das UMTS-Mobilfunknetz der Streithelferin für den Zugriff auf den RACH nicht zwischen mehreren Nutzerklassen. Entgegen der Auffassung der Klägerin seien die *Access Classes* in UMTS ohnehin keine patentgemäßen Nutzerklassen, da sie eine andere Funktion hätten. So gebe es beispielsweise nach der Lehre des Patents Mobilstationen, die keiner Nutzerklasse zugewiesen seien. In UMTS seien hingegen sämtliche Mobilstationen einer der Nutzerklassen 0 bis 9 zugewiesen. Hieran zeige sich die unterschiedliche Funktionalität der *Access Classes* und der patentgemäßen Nutzerklassen.

Soweit die Mobilstation nach Merkmal 2a dazu eingerichtet sein müsse, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, liege bereits deshalb keine Verwirklichung des Merkmals durch die angegriffenen Ausführungsformen vor, weil die Beklagten keine SIM-Karten vertrieben. Zudem meine der Wortlaut allein die im Prioritätszeitpunkt existenten SIM-Karten des GSM-Standards 11.11, Version 7.2.0 oder früher. Die nach dem UMTS-Standard arbeitenden Mobiltelefone verwendeten überdies keine SIM- sondern USIM-Karten.

Des weiteren sei auch Merkmal 2b nicht verwirklicht, weil es erfordere, dass die Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen in einem einheitlichen Datenstrom zeitgleich übertragen würden, wie das in Figur 3c dargestellte 13-Bitmuster zeige. Dies sei im UMTS-Standard jedoch nicht der Fall, weil der Persistenzlevel N und die Information *AC to ASC Mapping* nicht gleichzeitig und auch nicht regelmäßig zeitversetzt gesendet würden. Die *AC to ASC Mapping*-Tabelle würde im System *Information Block 7*, der Persistenzlevel N zeitlich getrennt im *System Information Block 5* oder *5bis* über den BCCH an die Mobilstation übermittelt. Nach der Lehre des Klagepatents müssten die Zugriffsschwellwertbits und der Zugriffsschwellwert inhaltlich stets identisch sein, was hinsichtlich der Parameter N und $P_i$ bzw. P(N) in UMTS nicht der Fall sei, da $P_i$ für jede ASC in der Mobilstation gesondert berechnet und skaliert werde. Trotz Identität von N sei der Wert $P_i$ unterschiedlich. Die Information *AC to ASC Mapping* sei zudem entgegen der Ansicht der Klägerin keine Zugriffsklasseninformation, sondern Teil der Zugriffsschwellwertbits, weil sie für die Ermittlung des Parameters $P_i$, den Schwellwert, verwendet würde.

Der Verwirklichung von Merkmal 2c stehe entgegen, dass bei UMTS nie der übertragene Persistenzwert N mit der Zufallszahl R verglichen werde, sondern vor dem Vergleich mit der Zufallszahl aus N mittels Skalierung mit dem optionalen Wert $s_i$ zunächst der *Persistence Value* $P_i$ abgeleitet werde. Erst dieser werde sodann mit der Zufallszahl R verglichen, was dem dem Klagepatent immanenten Egalitätsprinzip in dem Sinne widerspreche, dass der empfangene Persistenzschwellwert nicht unterschiedslos für alle Mobilstationen gelte, d.h. nicht alle Mobilstationen die gleichen Gewinnchancen bei der Zugriffslotterie hätten, weil $P_i$ für jede ASC gesondert in der Mobilstation berechnet werde. Der Wortlaut erlaube eine solche zusätzliche Skalierung indes nicht.

Insbesondere fehle es jedoch an einer Verwirklichung der Merkmalsgruppe 2d.
Im UMTS-Standard sei die vom Klagepatent vorgesehene strenge Alternativität nicht gegeben. Die von der Klägerin herangezogene Figur 11.2.2.1 ETSI 125 321 sei dabei ohnehin nur ein Implementierungsvorschlag und könne daher schon nicht herangezogen werden, um die Verletzungsfrage darzulegen. Selbst für den Fall ihrer Verbindlichkeit sei nach dem dort beschriebenen Verfahren die vom Patent beschrieben Alternativität nicht vorgesehen. Vielmehr werde in UMTS der Persistenzwert $P_i$ immer mit der Zugriffszahl R verglichen, sodass auch für die ASC#0 die Zugriffsberechtigung nicht unabhängig von

den empfangene Zugriffsschwellwertbits ermittelt werde. Der von der Klägerin für die Darlegung der Verletzung herangezogene Ablauf in UMTS habe allein die Funktion eines Verzögerungsgliedes, entscheide aber nicht über das „Ob“ des Zugriffs. Dies werde in UMTS vielmehr über das *Access Class Barring* gesteuert. Der in Anspruch genommene Mechanismus wolle nur durch die zeitliche Entzerrung der Zugriffe die Überlastsituation entzerren. Überdies werde im UMTS-Mobilfunknetz der Streithelferin kein dynamischer Persistenzlevel N übertragen, sondern netzwerkseitig im SIB7 ein fester Wert 1 gesendet. Somit werde der im SIB7 fest vorgegebene Wert in keinem Fall für den Zugriff auf den RACH relevant.

Die erfinderische Lehre stelle sich insbesondere vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Betrachtung der Stand der Technik darstellenden Dokumente GSM 138 (Anlage B9/D4)und GSM 04.60 (Anlage B9/D6) sowie IS 95 (Anlage B9/D11) nicht als erfinderisch dar. Auch gegenüber dem Stand der Technik ARIB Standard RCR STD-32 A (Anlage ROKH1/TD1) beruhe der Gegenstand des Klagepatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zudem liege eine unzulässige Erweiterung vor. Das Klagepatent sei erschlichen worden, da die Klägerin im Erteilungsverfahren das Dokument GSM 04.60 bewusst verschwiegen habe.

Der geltend gemachte Unterlassungs- und Schadensersatzantrag seien zu unbestimmt und damit unzulässig, die im Rahmen des Rechnungslegungsantrags geforderte Belegvorlage unverhältnismäßig, Angaben zu Einkaufspreisen (Antrag I.2.a)) und den Verkaufsstellen (Antrag I.2.b)) könnten allenfalls ab Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes geltend gemacht werden. Ferner können nur entweder Entfernung oder der Rückruf begehrt werden nicht aber beides zugleich. Die Vernichtung sei unverhältnismäßig, die Beklagte zu 1 habe weder Eigentum noch Besitz an den angegriffenen Ausführungen. Ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des Urteils sei nicht dargetan.

Der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis für die Klage, weil sie in dem beim Oberlandesgericht Karlsruhe anhängigen Rechtsstreit Az.: 6 U 66/09 als Nebenintervenientin behaupte, Vertragspartner eines Lizenzvertrages mit den Beklagten zu sein, der unter anderem auch das Klagepatent bzw. dessen Stammpatent und verbundene Schutzreche zum Gegensand habe. Daher fehle der Klägerin das Rechtsschutzbedürfnis, einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen.

Der Durchsetzung der Klageansprüche könnten die Beklagten den Lizenzeinwand entgegenhalten. Denn die Beklagten würden durch die Klägerin unzulässigerweise diskriminiert.

Die Robert Bosch GmbH, von der die Klägerin das Patentportfolio erworben habe, habe im Rahmen des ETSI Standardisierungsverfahrens eine generelle FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben, die alle in den UMTS-Standard aufgenommenen Schutzrechte und somit auch das Klagepatent als ein Teil der Patentfamilie EP 1 186 189 umfasse (Anlage B 33). Hieran sei auch die Klägerin gebunden. Die Beklagten hätten nämlich auf der Grundlage der von der Robert Bosch GmbH abgegebenen FRAND-Verpflichtungserklärung nach französischem Recht ein Nutzungsrecht an dem Klagepatent. Diese habe die Klägerin durch ihre FRAND-Erklärung (Anlage B 37) ausdrücklich übernommen.
Unabhängig davon hätten die Beklagten jedenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen, den die Beklagten dem Unterlassungsanspruch gemäß § 242 BGB entgegenhalten könnten.
Zudem ergebe sich der Lizenzeinwand aus dem kartellrechtlichen Diskriminierungs- sowie aus dem Kartellverbot. Die patentrechtlichen Rahmenbedingungen würden von der Klägerin durch systematische Teilanmeldungen missbraucht.
Rechtsmissbräuchlich sei die Durchsetzung des Klagepatents auch aufgrund eines Patent Ambushs und schließlich stelle sich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als unverhältnismäßig dar.
Die Klägerin sei verpflichtet, der Widerklägerin eine Lizenz an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Ein entsprechendes Angebot liege mit der Anlage B 55 vor, das die Klägerin nicht ablehnen dürfe, ohne gegen das Diskriminierungs- und Behinderungsverbot zu verstoßen. Die Klägerin sei daher gemäß § 33 GWB zur Annahme des vorgelegten Angebots verpflichtet.

Die Streithelferin trägt vor,
sie betreibe in Deutschland u.a. ein UMTS-Mobilfunknetz, in dem die angegriffenen Telefone der Beklagten operieren könnten. Die Klage richte sich auch gegen Geräte, die von der Streithelferin vertrieben würden, welche sie von den Beklagten beziehe. Sie sehe sich daher möglichen Regressansprüchen der Beklagten ausgesetzt, weshalb ein rechtliches Interesse bestehe, das sie zum Streitbeitritt berechtige. Dieses Interesse

ergebe sich überdies schon aus der Streitverkündung selbst und aus dem Umstand, das ihr möglicherweise Regressansprüche zustünden, wenn die Beklagten nicht mehr in der Lage sein sollten, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll über die mündliche Verhandlung ergänzend Bezug genommen.
Die Parteien haben zuletzt durch nicht nachgelassene Schriftsätze vom 20.01.2011 (Klägerin und Beklagte), vom 01.02.2011 (Klägerin) und vom 10.02.2011 (Beklagte) Vortrag gehalten.

# Entscheidungsgründe

## A.
## Entscheidungszuständigkeit

### I.

Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind dem Vorwurf ausgesetzt, bundesweit den deutschen Teil des Europäischen Patents EP 1 841 268 zu verletzen, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.

### II.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Kammer auch hinsichtlich des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs nach § 33 PatG zur Entscheidung berufen. Der eine Zuständigkeit nach § 32 ZPO, Art. 5 Nr. 3 EuGVVO für den Entschädigungsanspruch ablehnenden Auffassung (Kühnen, GRUR 1997, 19 ff.) tritt die Kammer nicht bei. Nach Auffassung der Kammer liegt dieser Auffassung ein zu enges Verständnis der zitierten Vorschriften zugrunde, die sie im wesentlichen unter Verweis auf die Entscheidung „*Offenendspinnmaschine*“ des Bundesgerichtshofs (BGHZ 107, 161, 164) damit begründet, die Benutzung einer offengelegten Erfindung stelle kein rechtswidriges, sondern ein durch das Gesetz erlaubtes Verhalten dar und werde daher nicht durch die benannten Vorschriften erfasst. Bereits diese Qualifikation ist indes nicht unbestritten (vgl. Pahlow GRUR 2008, 97 ff. m.w.N.).
Sinn und Zweck der Schaffung einer besonderen Zuständigkeit desjenigen Gerichts, in dessen Zuständigkeitsbereich der Handlungs- und/oder Erfolgsort einer deliktischen Handlung fällt, ist die Erleichterung der Prozessführung für den Deliktsgläubiger, der die Vorteile des orts- und beweisnahen Gerichts soll nutzen dürfen (Musielak/Heinrich, ZPO, 7. Aufl. 2009, § 32 Rn. 1). In negativer Hinsicht kann die Anwendbarkeit des § 32 ZPO daher ausgeschieden werden, wenn es sich um eine Klage handelt, die eine Form der Vertragsverletzung zum Gegenstand hat. Hingegen wird jedenfalls in Fällen der bereicherungsrechtlichen Eingriffskondiktion eine Anwendbarkeit des § 32 ZPO bejaht, da diese eine Form unerlaubter, der Rechtsordnung zuwiderlaufende Handlung darstelle (Musielak/Heinrich, ZPO, 7. Aufl. 2009, § 32 Rn. 7 m.w.N.; Zöller/Vollkommer, ZPO, 28.

Aufl. 2010, § 32 Rn. 9). Selbst wenn man daher mit der Ansicht des Bundesgerichtshofs die Benutzung einer offengelegten Erfindung als erlaubtes Verhalten ansieht, zwingt dies nicht dazu, bereits aus diesem Grund eine Zuständigkeit nach § 32 ZPO und dem autonom auszulegenden Art. 5 Nr. 3 EuGVVO zu verneinen. Denn der Entschädigungsanspruch erscheint - obwohl kein Schadensersatz- oder Bereicherungsanspruch im eigentlichen Sinne - dem Anspruch aus Eingriffskondiktion jedenfalls insoweit vergleichbar als hier wie dort aus dem Zuweisungsgehalt eines Rechts Ansprüche gegen den Eingreifenden bzw. Benutzenden geltend gemacht werden können, da das Recht wirtschaftlich dem Inhaber bzw. Patentanmelder zugewiesen ist. Aus einer formalistischen, auf die Rechtsnatur des Entschädigungsanspruchs verweisenden Auffassung ergäbe sich eine nach Ansicht der Kammer nicht sachgerechte Aufspaltung der gerichtlichen Zuständigkeit für die Entscheidung über den Entschädigungsanspruch einerseits und Schadensersatzansprüche andererseits, die die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen in sich trägt. Insoweit verweist *Kraßer* (vgl. ders., Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 898 für eine analoge Anwendung des § 32 ZPO plädierend) zutreffend darauf, dass die Klage oftmals erst nach Erteilung des Patents erhoben wird und in der Regel im Wege der objektiven Klagehäufung der Entschädigungs- und der Schadensersatzanspruch in einem Rechtsstreit geltend gemacht werden. Es ist kein mit dem Regelungsziel von § 32 ZPO vereinbarer Grund ersichtlich, denjenigen, der das dem Patentanmelder zustehende Recht auch vor der Erteilung genutzt hat, dadurch zu begünstigen, dass der Verletzte seine Rechte aus der ihm gebührenden Erfindung vor unterschiedlichen Gerichten durchsetzen muss.

Diese Erwägungen gelten für die autonom auszulegende Vorschrift des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO, aus der sich die Zuständigkeit der Kammer für die gegen die Beklagte Ziffer 1 geltende gemachten Ansprüche ableitet, in gleicher Weise wie für § 32 ZPO, aus dem die Zuständigkeit der Kammer für die gegen die Beklagte Ziffer 2 gerichteten Ansprüche folgt.

## B.

## Keine Aussetzung nach Artt. 27 Abs. 1, 30 Nr. 1 EuGVVO

Das Verfahren ist nicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO auszusetzen.

I. Nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO hat das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen auszusetzen bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, wenn bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden.

II. Zwar haben die hiesigen Beklagten am 26.02.2010 vor dem Tribunale di Milano Klage auf Feststellung der Nichtverletzung des italienischen und deutschen Teils der europäischen Patentanmeldung bzw. des europäischen Patents EP 1 841 268 erhoben (Anlage K 72), die am 10.03.2010 dort eingegangen ist (vgl. Stempel Anlage B 5b, Anlagenband II C). Indessen hat die Klägerin das Landgericht Mannheim bereits am 05.02.2010 und damit zeitlich vorher angerufen.

1. Auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der jeweiligen Verfahren kommt es dabei nach der Konzeption der EuGVVO nicht an (vgl. Erwägungsgrund 15 VO (EG) 44/2001; MünchKomm-ZPO/Gottwald, 3. Aufl. 2008, Art. 30 EuGVO Rn. 1 f.). Die Anrufung wird durch Art. 30 EuGVVO näher definiert und ist autonom zu entscheiden, wobei nach Nr. 1 der Vorschrift ein Gericht zu dem Zeitpunkt als angerufen gilt, zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstück bei Gericht eingereicht worden ist. Erforderlich ist, dass der Kläger es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die Zustellung des Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken, wodurch wiederum auf die jeweilige lex fori zurückgegriffen wird, nach deren Rechtssystem diese Frage zu entscheiden ist (OLG Karlsruhe, OLGR 2006, 714).

2. Vorliegend hat die Klägerin alles nach diesen Maßstäben Erforderliche getan. Sie hat ausweislich der Akten dem Schriftsatz, durch den die Klage um das Klagepatent erweitert wurde, einen Verrechnungsscheck über € 22.368,- beigefügt (vgl. Vermerk der Geschäftsstelle AS 1), wobei der aus einem Streitwert von € 2.000.000,-- berechnete Betrag ausweislich der Zahlungsanzeige der Landesoberkasse am 09.02.2010 eingezahlt und am 15.02.2010 gebucht wurde (AS VI). Damit hat die Klägerin der Vorschrift des § 12 Abs. 1 S. 2 GKG genügt, wonach eine Klageerweiterung erst nach Zahlung der Gebühr zugestellt werden soll. Entsprechend hat der Vorsitzende die Zustellung der Klageerweiterung durch Verfügung vom 08.02.2010 (AS 31) angeordnet.

3. Insoweit greift der Einwand der Beklagten nicht durch, die Zustellung hätte nicht erfolgen dürfen, weil die Klägerin den Gebührenausschuss nur aus einem offenkundig untersetzten Streitwert entrichtet habe. Die Klägerin hat der Ordnungsvorschrift des § 61 GKG (Binz/Dörndorfer, Gerichtskostengesetz, 2. Aufl. 2009, § 61 Rn.1) entsprochen und einen vorläufigen Streitwert von € 2.000.000 als ihrer Ansicht nach zutreffenden Streitwert angegeben, aus dem sie die Gebühr entrichtet hat. Der so angesetzte vorläufige Streitwert wurde auch von dem die Zustellung verfügenden Gericht nicht beanstandet, sondern auf dieser Grundlage die Zustellung der Klageerweiterung bewirkt.

4. Im Ergebnis geht ferner die Argumentation der Beklagten fehl, die Klägerin habe deshalb nicht die ihr nach Art. 30 Nr. 1 EuGVVO obliegenden Maßnahmen getroffen, weil sie die Klageerweiterung in dem ausgesetzten Verfahren 7 O 182/08 vorgenommen habe. Die Prozesshandlung sei nämlich nach § 249 Abs. ZPO unwirksam. Vorliegend muss nicht die Frage entschieden werden, ob Art. 30 EuGVVO die von den Beklagten als unzulässig gerügte Prozesshandlung der Klägerin überhaupt in den Blick nimmt, denn jedenfalls liegt ein Verstoß nicht vor. § 249 Abs. 2 ZPO betrifft nämlich nur Prozesshandlungen die „in Ansehung der Hauptsache“ vorgenommen wurden. Vorliegend hingegen wurde die Klage um einen weiteren Streitgegenstand erweitert und folglich keine Handlung vorgenommen, die die ausgesetzte Hauptsache betraf (vgl. MünchKomm-ZPO/Gehrlein, 3. Aufl. 2008, § 249 Rn. 19). Zudem wäre ein Mangel jedenfalls nach § 295 Abs. 1 ZPO geheilt, weil die Beklagten die Zustellung der Klageerweiterung in ihrem Schriftsatz vom 18.02.2010 (AS 33 ff.) ausdrücklich genehmigt haben.

5. Es kann somit offen blieben, ob das vor dem Tribunale di Milano angestrengte Verfahren überhaupt denselben Anspruch im Sinne von Art. 27 Abs. 1 EuGVVO betrifft, wobei der Begriff des Anspruchs i.S.d. autonom auszulegenden Vorschrift nicht mit dem Streitgegenstandsbegriff nach deutschem zivilprozessualen Verständnis identisch ist (für eine vergleichbare Konstellation verneinend LG Düsseldorf, GRUR-RR 2009, 402 ff.), und ob möglicherweise mangels Kognitionsbefugnis des italienischen Gerichts hinsichtlich einer Verletzung über den deutschen Teil eines Europäischen Patents im Hinblick auf Art. 6 EMRK ein Fall so evidenter Unzuständigkeit des Tri-

bunale di Milano vorliegt, dass eine Aussetzung ungeachtet der Grundsätze, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft etabliert hat (vgl. EuGH 9.12.2003 C-116/02, EuZW 2004, 2004, 188; EuGH Urt. v. 27.04.2004 C-159/02 - *Turner/Grovit*, IPRax 2004, 425; EuGH SchiedsVZ 2009, 120), zu unterbleiben hätte (vgl. hierzu BGH NJW 2002, 2795).

## C.
## Klage

Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet. Die Beklagten verletzen das Klagepatent (I.), wohingegen die gegen die geltend gemachten Ansprüche erhobenen Einwendungen nicht durchgreifen (II.). Hieraus rechtfertigen sich ganz überwiegend die von der Klägerin begehrten Rechtsfolgen (III.).

### I.
### Patentverletzung

Die Beklagten verletzen das Klagepatent gem. Art 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG, weil sie von Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch machen.

1. Das Klagepatent betrifft den Zugriff einer Mobilstation auf einen wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse.

a) Es kennzeichnet im Stand der Technik Verfahren zur Zugriffskontrolle auf einen Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes für mindestens eine Teilnehmerstation, wobei Informationssignale an diese übertragen würden, als bekannt. Ebenso sei aus der US 4,707,832 ein *local area network* bekannt, das einen gemeinsamen Steuerkanal benutze, über den Steuermeldungen zwischen Modems innerhalb des Netzwerks ausgetauscht würden. Zusätzlich sei eine Vielzahl von Datenkanalpaaren vorhanden, wobei die Zuteilung der Datenkanäle von dem erfolgreichen Gebrauch des Steuerkanals abhänge, wozu ein vorgegebenes Steuerkanalzugangsschema verwendet würde. Hiernach müsse jeder anfordernde Knoten eine ak-

kumulierte Aktivitätsmessung mit einer Verkehrsdichtenschwelle vergleichen, die kontinuierlich an die aktuelle Steuerkanalaktivität angepasst werde. Der Steuerkanal bliebe für den anfordernden Benutzerknoten gesperrt, solange die akkumulierte Messung geringer sei als die Schwelle.
Aus der WO 97/19525 sei ein drahtloses Kommunikationssystem bekannt, das die begrenzte Anzahl der Kanäle für eine Funkzelle mit einer Basisstation derart verwalte, dass zur Vermeidung von Überlastungssituationen von der Basisstation die Anzahl der Zugriffsversuche ermittelt und Werte für die Zugriffswahrscheinlichkeit an die einzelne Teilnehmerstationen über einen gemeinsamen *broadcast channel* oder Steuerkanal übertragen würden. Die empfangende Teilnehmerstation wähle aus diesen Werten eine ihrer Prioritätsklasse entsprechenden Wert aus und vergleiche ihn mit einer Zufallszahl, um festzustellen, ob ihr ein Zugriff auf den Kommunikationskanal erlaubt sei. Gemäß der Schrift WO 98/23109 werde der Überlastungsschutz in einem zellularen Netzwerk durch eine zweistufige Adaption der Persistenz einer Mobilstation realisiert. EP 0765096 A2 offenbare eine Zugriffsmethode in einem CDMA-Mobilfunksystem, wobei die Mobilstation mit den zu übertragenden Daten ein Übertragungsanforderungssignal über eine Zugriffskanal sende, die Basisstation ein Übertragungsbewilligungssignal übermittle, welches für die Übertragung die Zeitsteuerung der Daten und einen für die Übertragung zu verwendenden Spreizcode zuweise, das vom Auslastungszustand des Signalisierungskanals und des Zustands der Häufigkeit der Daten abhänge. In Tdoc SMG2 UMTS-L23 535/98 schließlich sei ein Algorithmus mit dynamischer Persistenz vorgeschlagen, der die Interferenzverwaltung und Minimierung der Verzögerung bezwecke, indem der Zugriff auf den RACH-Kanal des Systems kontrolliert werde. Das System verbreite über einen gemeinsamen Downlink-Kanal einen vom geschätzten Backlog der Systemnutzer abhängigen Persistenzwert. Dieser werde vom UE gelesen und übertrage ihn auf dem nächst verfügbaren RACCH-Slot mit einer Wahrscheinlichkeit p. Wenn sich ein Stau auf dem RACH im System ergebe, werde der Persistenzwert reduziert, wodurch die Anzahl der aktiven Benutzer auf dem RACH reduziert werde. Umgekehrt werde der Persistenzwert in den inaktiven Zeitabschnitten erhöht, sodass die Zugriffsverzögerung verbessert werde.

b) Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als Vorteil seiner erfinderischen Lehre, dass sich mit ihr eine zufällige Verteilung der Zugangsberechtigung zu dem Tele-

kommunikationskanal für eine oder mehrere Teilnehmerstationen realisieren lasse, wobei die Zugriffskontrolle lediglich die Übertragung des Zugriffsschwellwerts erfordere und daher ein Minimum an Übertragungskapazität in Anspruch nehme. Besonders vorteilhaft sei es, wenn in der Auswerteeinheit der Teilnehmerstation geprüft werde, ob die Zugriffsberechtigungsdaten Zugriffsberechtigungsinformationen und Zugriffsklasseninformationen für mindestens eine vorgegebene Nutzerklasse, der die Teilnehmerstation zugeordnet sei, umfassten, wobei der Zugriff auf einen Telekommunikationskanal von der Zugriffsklasseninformation für die betreffende Nutzerklasse abhängig sei. So könnte Teilnehmerstationen bestimmter Nutzerklassen der Zugriff auf den Kanal gewährt werden, selbst wenn sie eigentlich aufgrund der zufälligen Verteilung mittels Zugriffsschwellwerts nicht zugreifen dürften. Diese Funktionalität lasse sich beispielsweise für Notrufdienste nutzen.

c) Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik werde durch eine Mobilstation nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:

(1) Mobilstation (5, 10, 15, 20) zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz,

(a) in dem mehrere Nutzerklassen (35, 40) unterschieden werden,

(2) die Mobilstation (5, 10, 15, 20) ist dazu eingerichtet,

(a) eine Nutzerklasse (35, 40) von einer SIM-Karte zu lesen

(b) über einen Broadcast Control Channel (25) Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) und Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu empfangen,

(c) aus den Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) eine Zugriffsschwellwert (S) zu ermitteln,

(d) anhand der für die Nutzerklasse (35, 40) relevanten Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu ermitteln,

(i) ob die Mobilstation (5, 10, 15, 20) unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, S0) auf einen wahlfreien Zugriffskanal, z.B. RACH, zugreifen darf,

(ii) oder ob die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal, z.B. RACH, in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird.

2. Die angegriffene Ausführungsform macht von sämtlichen Merkmalen wortsinngemäßen Gebrauch.

a) Bei den von den Beklagten vertriebenen Mobiltelefonen handelt es sich um Mobilstationen, die im Sinne des Merkmals 1 zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz geeignet sind.

aa) Die von den Beklagten vertriebenen Mobiltelefone sind UMTS-fähig und damit zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz geeignet. Die Argumentation der Beklagten, Merkmal 1 sei nicht verwirklicht, weil es darauf ankomme, dass die Mobiltelefone in dem im Prioritätszeitraum existenten UMTS-Netz betreibbar seien, was nicht der Fall sei, weil die vertriebenen Mobiltelefone nicht rückwärtskompatibel seien und nicht in dem damals aktuellen UMTS Release 1999 arbeiten könnten, greift patentrechtlich zu kurz. Bereits nach dem Wortlaut beschränkt sich der Anspruch nicht auf den UMTS-Standard, der im Prioritätszeitpunkt aktuell war. Vielmehr ist nur erforderlich, dass die Mobilstation in „einem“ UMTS Mobilfunknetz betreibbar ist. Nur insoweit hat die Funktionalitätsangabe mittelbare Bedeutung für den Schutzbereich des geltend gemachten Vorrichtungsanspruchs (vgl. BGH GRUR 2009, 837 - *Bauschalungsstütze*). Der Fachmann erkennt, dass sich der Schutzanspruch nicht auf den UMTS Standard in der Version Release 1999 beschränken soll, weil ihm bekannt war, dass der UMTS-Standard ständigen Wandelungen und Fortschreibungen unterliegt, der umgekehrt auch die Funktionalitäten der nach ihm arbeitenden Vorrichtungen beeinflusst. Der Fachmann erkennt als notwendig nur, dass das UMTS-Netz zellular aufgebaut sein (vgl. Klagepatentschrift [0016]) und einen wahlfreien Zugriffskanal und einen Signalisierungskanal aufweisen muss (vgl. Klagepatentschrift [0017]). Dafür dass sich der Schutzbereich auf ein UMTS-Mobilfunknetz einer bestimmten Version beschränken würde, findet der Fachmann indes in der Beschreibung und den Zeichnungen keinerlei Anhaltspunkte. Im Gegenteil findet er seine Auffassung, dass der in Merkmal 1 verwendete Begriff des UMTS-Mobilfunknetzes weit zu verstehen ist, durch den Hinweis in der Patentschrift bestätigt, dass „das erfindungsgemäße Verfahren [...] in einem Mobilfunknetz nach dem UMTS-Standard [...], nach GSM-Standard, oder dergleichen realisiert werden“ könne (Klagepatentschrift Sp. 14 Z. 54 ff.). Diesen Hinweis versteht er als Indiz für die Richtigkeit seiner Annahme, dass der Wortlaut des Merkmals 1 den Schutzbereich des Anspruchs nicht auf eine bestimmte Version des UMTS-Standards beschränken will.

bb) Soweit das UMTS-Mobilfunknetz verschiedene Nutzerklassen unterscheiden muss (Merkmal 1a)), ist auch dieses Merkmal erfüllt. Nach Auffassung der Kammer sind die im UMTS-Standard (ETSI TS 122 011, Abschn. 4.2, Anlage K 11) vorgesehenen Access Classes patentgemäße Nutzerklassen. Hierfür ist lediglich erforderlich, dass die im Netz arbeitenden Mobilstationen nach abstrakten Kriterien einer vorgegebenen Nutzerklasse (vgl. Klagepatentschrift [0010]) zugeordnet werden. Dieses Erfordernis findet der Fachmann im UMTS-Standard an zitierter Stelle wieder, wenn er dort erfährt, dass alle Mobilstationen einer von zehn Gruppen zugeordnet werden, die auf der SIM/USIM gespeichert sind und u.U. die Mobilstationen fünf weiteren speziellen Kategorien angehören können.

Irrelevant ist indes, ob in den derzeit betriebenen Mobilfunknetzen tatsächlich von dieser im Standard vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, weil dies die Fähigkeit der angegriffenen Ausführungsform, standardgemäß zu arbeiten, nicht in Frage stellt. Daher ist ohne Belang, ob im UMTS-Netz, das die Streithelferin betreibt, alle Mobilstationen auf die ASC#0 gemappt sind. Ebenso ist ohne Belang, ob das Patent Mobilstationen kennt, die keiner Nutzerklasse zugeordnet sind (vgl. Klagepatentschrift [0031]) oder umgekehrt der UMTS-Standard zusätzliche Nutzerklassen kennt, denen die Mobilstation angehören kann, ohne dass dies im Patent Entsprechung finden würde. Insoweit erschöpft sich die Argumentation der Beklagten in dem Postulat, die klagepatentgemäßen Nutzerklassen seien etwas anderes, ohne dass eine Begründung für diese Auffassung gegeben wird noch sonst ersichtlich ist.

b) Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen weiter Merkmal 2a, weil sie dazu eingerichtet ist, eine patentgemäße Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen. Ausweislich des UMTS-Standards TS 122 011, Abschnitt 4.2 (Anlage K 11) wird die der Mobilstation zugewiesene Access Class als patentgemäße Nutzerklasse auf der SIM/USIM gespeichert. Das Klagepatent beschreibt dabei, dass die Auswerteeinheit der Mobilstation auf eine Zugriffsberechtigungskarte 75 zugreift, die „beispielsweise eine SIM-Karte“ (vgl. Klagepatent Z. 7 Sp. 27 f.) sein könne. Da der Wortlaut lediglich verlangt, dass die Mobilstation „dazu eingerichtet“ ist, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, ist auch irrelevant, dass die Beklagten selbst keine Mobilfunkgeräte mit SIM-Karten vertreiben. Entscheidend ist allein, dass die von den Beklagten vertriebenen Mobilstationen die entsprechende Funktionalität aufweisen. Da der Fachmann anhand der vorzitierten Stelle in der Beschreibung des Klagepatents

erkennt, dass der dort verwendete Begriff der SIM-Karte seiner Funktion nach eine Zugriffsberechtigungskarte in den Blick nimmt und ihm zudem kraft seines allgemeinen Fachwissens bekannt ist, dass entsprechende Zugriffsberechtigungskarten, die im UMTS-Netz verwendet werden, als USIM-Karten bezeichnet werden, ist patentrechtlich ebenfalls ohne Belang, dass im UMTS-Netz USIM- und keine SIM-Karten eingesetzt werden. Dass die Begriffe insoweit synonym verwendet werden, ist gerade aus dem zitierten UMTS-Standard ersichtlich, der selbst ausführt, die Access Class sei in der „SIM/USIM" gespeichert (a.a.O. Abschnitt 4.2) Aus den bereits zu Merkmal 1 dargelegten Gründen erkennt der Fachmann zudem, dass sich der Anspruch nicht wie die Beklagten meinen etwa nur auf die im Prioritätszeitpunkt verwendete SIM-Karte nach dem GSM-Standard 11.11, Version 7.2.0 oder früher beschränkt.

c) Ferner machen die angegriffenen Ausführungsformen auch von <u>Merkmal 2b</u> wortsinngemäßen Gebrauch.

aa) Der Fachmann erkennt in dem Parameter „*AC to ASC Mapping*", der nach dem UMTS-Standard im *System Information Block 5* bzw. *5bis* übertragen wird, eine patentgemäße Zugriffsklasseninformation (vgl. ETSI TS 125 331, Abschn. 8.5.12 und 8.5.13, Anlage K 10).

Der Beschreibung (vgl. [0027]) entnimmt der Fachmann, dass das Patent als Zugriffsklasseninformation eine solche Signalisierung begreift, die für eine bestimmte Nutzerklasse relevant ist. Eben diese Funktionalität weist der Parameter *AC to ASC Mapping* auf, der in Abschnitt 8.5.13 des ETSI TS 125 331 beschrieben wird. Es ist ersichtlich, dass den *Access Classes* als patentgemäßen Nutzerklassen jeweils eine *Access Service Class* zugeordnet wird. Diese Beziehung wird durch die Argumentation der Beklagten, der Parameter *AC to ASC Mapping* fließe in die Ermittlung des Persistenzwerts $P_i$ ein, nicht in Frage gestellt. Selbst wenn dies der Fall wäre, so stellte dies den Umstand nicht in Frage, dass der Parameter nach dem Standard für definierte Nutzerklassen bestimmte Informationen enthält, die sodann für den Zugriff auf den RACH relevant sind (vgl dazu bei e).

bb) Zudem findet der Fachmann in dem Persistenzniveau N, der im *System Information Block 7* übertragen wird (TS 125 331, Abschnitt 8.5.12, Anlage K 10), eine Entsprechung der patentgemäßen Zugriffsschwellwertbits, die über den RACH gesendet,

von der Mobilstation empfangen werden und sodann Eingang in die Ermittlung des Zugriffsschwellwerts finden (vgl. sogleich bei c).

cc) Er erkennt dabei, dass es bei funktionaler Betrachtung allein darauf ankommt, dass beide in Merkmal 2b vorgestellten Parameter in dem Zeitpunkt für die Mobilstation verfügbar sein müssen, zu dem sie auf den RACH zugreifen möchte. Das Verständnis der Beklagten, wonach die Zugriffsklasseninformationen und die Zugriffsschwellwertbits zur selben Zeit und gemeinsam in einem einheitlichen Datenstrom gesendet werden müssen, was aus der das 13-Bitmuster darstellenden Figur 3c ersichtlich sei, ist patentrechtlich unzutreffend. Weder dem Wortlaut des Merkmals 2b noch der Beschreibung lässt sich entnehmen, dass nur eine zeitgleiche Übertragung im selben Datenstrom patentgemäß wäre. Soweit in der Figur 3c die entsprechenden Parameter dem Postulat der Beklagten entsprechen, erkennt der Fachmann, dass es sich hierbei um ein bloßes Ausführungsbeispiel handelt, das den Schutzbereich nicht beschränkt (vgl. Klagepatent [0034]).

d) Auch das <u>Merkmal 2c</u> wird von den angegriffenen Ausführungsformen wortsinngemäß verwirklicht, weil in den UMTS-fähigen Mobilstationen der Beklagten aus den übertragenen Zugriffsschwellwertbits ein Zugriffsschwellwert (S) ermittelt wird. So wird nach dem Standard aus dem Parameter N über die feststehende Beziehung $P(N) = 2^{-(n-1)}$ der für die Zugriffsschwellwertauswertung verwendete Zugriffsschwellwert $P(N)= P_i$ ermittelt. Ob für die ASC#2-7 zusätzlich im Zuge der Ermittlung ein Skalierungsfaktor $s_i$ berücksichtigt wird (vgl. ETSI TS 125 331, Abschnitt 8.5.12), ist ohne Belang, weil der Schutzbereich des Patents nach dem Anspruchswortlaut nicht darauf beschränkt ist, dass der Zugriffsschwellwert ausschließlich aus den übertragenen Zugriffsschwellwertbits ermittelt wird. Soweit die Beklagten entgegenhalten, dass durch die Skalierung niemals die Zufallszahl R, sondern erst der durch den Skalenfaktor $s_i$ beeinflusste und für jede ASC gesondert berechnete Wert $P_i$ mit R verglichen würde und hierdurch dem Egalitätsprinzip des Klagepatents widersprochen werde, wonach der empfangene Schwellwert unterschiedslos für alle Mobilstationen

gelten solle und alle Mobilstationen die gleichen „Gewinnchancen in der Zugriffslotterie“ haben müssten, findet diese Auffassung im Klagepatent keine Stütze.

e) Schließlich wird nach der Auffassung der Kammer auch die Merkmalsgruppe 2d durch die angegriffenen Ausführungsformen wortsinngemäß verwirklicht.

aa) Nach dem für die Darlegung der Verletzungsfrage herangezogenen UMTS-Standard erhält die Mobilstation über den Parameter *AC to ASC Mapping* die Information, welche *Access Service Class* der aus der (U)SIM-Karte ausgelesenen *Access Class* zugewiesen ist. Für die ASC#0 darf die Mobilstation nach Auffassung der Kammer im Sinne des Merkmals 2d (i) unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf den wahlfreien Zugriffskanal zugreifen, wobei dies anhand der für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformation ermittelt wird. Denn der Parameter *AC to AC Mapping* stellt die patentgemäße Zugriffsklasseninformation dar (vgl. oben bei c) aa), anhand der für die nach dem Standard vorgesehenen Nutzerklassen „ermittelt" wird, ob der Zugriff nach dem Weg des Merkmals 2d (i) oder 2d (ii) erfolgt. Ist der betreffenden *Access Class* der Mobilstation ASC#0 zugeteilt, so ist nach dem Standard der Persistenzwert $P_i$ auf 1 gesetzt (vgl. TS 125 331 Abschn. 8.5.12, Anlage K 10) und damit die Bedingung für den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal nach der Figur 11.2.2.1 des ETSI TS 125 321 (Anlage K 9) immer erfüllt, weil der Zugriff immer möglich ist, wenn $R \leq P_i$, wobei $0 \leq R < 1$ gilt. Sofern $P_i$ auf 1 gesetzt ist, ist $P_i$ immer größer als R, weil R seinerseits stets kleiner als 1 ist. Aus Sicht der Kammer steht der Verwirklichung des Merkmals nicht entgegen, dass auch für die ASC#0 ein Vergleich des auf 1 gesetzten Persistenzwert $P_i$ mit der gezogenen Zufallszahl R stattfindet, weil auch dann die Entscheidung über den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits erfolgt. Patentrechtlich entscheidend ist nach Merkmal 2d (i) nur, dass die Entscheidung über den Zugriff nicht mehr von der Zugriffsschwellwertbestimmung abhängt, wie Merkmal 2d (ii) es vorsieht. Das Verständnis der Beklagten, die den Wortlaut „unabhängig von" im Sinne einer Nichtauswertung verstehen, und das Merkmal deshalb nicht als gegeben ansehen, weil immer ein Abgleich des Persistenzwerts $P_i$ mit R stattfinde, greift bei der gebotenen, am technischen Sinngehalt der in der Patentschrift verwendeten Worte anknüpfenden Auslegung des Wortlauts (BGHZ 150, 149, 156 - *Schneidmesser I*; BGH GRUR 1999, 909 - *Spannschraube*) zu kurz. Denn als Vorteil der Erfindung wird in der Beschreibung gerade herausgestellt, dass es aufgrund der erfinderischen Lehre möglich sei, Teilnehmerstationen einer vorgegebenen Nutzerklasse selbst dann zur Nutzung des Kanals zuzulassen, wenn sie auf-

grund der zufälligen Verteilung mittels des Zugriffsschwellwerts eigentlich nicht zugriffsberechtigt wären, sie indes einer bevorzugten Nutzerklasse zugeordnet werden, die unabhängig von der zufälligen Verteilung durch die entsprechenden Zugriffsschwellwertinformationen auf den Kanal zugreifen dürfen (vgl. Klagepatentschrift [0019]. Dieser erfindungsgemäße Vorteil wird indes durch das beschriebene Verfahren ebenso erreicht, selbst wenn gleichsam „im Leerlauf“ als Standardprozedur immer ein Abgleich von Zufallszahl und Persistenzwert stattfindet, indes aufgrund des der Nutzerklasse zugewiesenen Persistenzwerts das Ergebnis des Abgleichs von vornherein feststeht. Das Klagepatent gibt insoweit aus Sicht der Kammer nicht vor, auf welche Art und Weise sichergestellt ist, dass die Zugriffsschwellwertbits auf die Entscheidung über den Zugriff keine Bedeutung haben (vgl. Klagepatentschrift Sp. 11 Z. 32 ff. und Z. 47 ff.).

bb) Die Argumentation der Beklagten, der Parameter *AC to ASC Mapping* sei auch ein Teil der Zugriffsschwellwertbits, weil das *AC to ASC Mapping* für die Ermittlung von $P_i$ verwendet werde, wenn der Wert für die verschiedenen ASC gesondert berechnet werde, führt aus Sicht der Kammer nicht dazu, dass der Parameter *AC to ASC Mapping* als „(Teil der) Zugriffsschwellwertbit(s)“ (vgl. AS 315 bei Tz. 125) zu qualifizieren wäre. Der Umstand, dass der Persistenzwert nach dem Standard für verschiedene *Access Service Classes* berechnet wird, nimmt dem Parameter aus Sicht der Kammer bei der am technischen Sinngehalt anknüpfenden Bestimmung seiner Funktion nicht die Eigenschaft einer patentgemäßen Zugriffsklasseninformation (vgl. oben c) aa).

cc) Ferner vermag die Ansicht der Beklagten nicht zu überzeugen, im Ergebnis sei der im Standard praktizierte Ablauf deshalb etwas anderes als das patentgemäße Vorgehen nach Merkmalsgruppe 2d, weil das standardgemäße Verfahren allein den Sinn habe, Überlastsituationen dadurch zu entzerren, dass die Zugriffe zeitlich entzerrt würden. Hingegen sei nach dem Standard die grundsätzliche Entscheidung, dass ein Zugriff erfolgen könne, bereits vorher getroffen worden. Es gehe nur noch darum, wann er konkret erfolgen dürfe. Diese Betrachtung ist patentrechtlich unzutreffend, weil der geltend gemachte Anspruch allein die konkrete Zugriffssituation auf den wahlfreien Zugriffskanal im Blick hat. Nach dem Vortrag der Beklagten ist indes über den konkreten Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal noch nicht entschieden,

wenn die jeweilige Teilnehmerstation sich noch in der von den Beklagten als Verzögerungsglied beschriebenen Warteschleife befindet. Die Entscheidung, ob auf den Kanal tatsächlich zugegriffen werden darf, erfolgt auch dann erst nach dem geschilderten Durchlaufen der im Standard vorgesehenen Prozedur.

dd) Patentrechtlich unerheblich ist daher auch, dass der Standard den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal auch noch über die zusätzliche Funktion des *Access Class Barring* steuert. Denn dies schließt nicht aus, dass dann, wenn eine bestimmte Nutzerklasse nicht bereits von vornherein ausgeschlossen ist, die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal patentgemäß erfolgt.

ee) Soweit die Beklagten schließlich die Verbindlichkeit der Figur 11.2.2.1 in Abrede stellen und sie als bloßen Implementierungsvorschlag verstanden wissen wollen, kann sich die Kammer auch dem nicht anschließen. Die Figur ist in einem Technical Standard (TS)-Dokument enthalten, das auf Verbindlichkeit ausgelegt ist. In der Anmerkung zu Beginn des Abschnitts 11.2.2 findet sich zudem der Hinweis, dass die Figur das sodann beschriebene Verfahren illustrieren soll, indes keine Beschränkungen für die Umsetzung daraus abgeleitet werden sollen. Der zwingende Charakter wird dadurch aus Sicht der Kammer indes nicht in Abrede gestellt, sondern lediglich klargestellt, dass bei Wahrung der zwingenden Vorgaben ein Implementierungsspielraum besteht, sodass die zwingenden Vorgaben in unterschiedlicher Weise und nicht nur auf einem Weg umgesetzt werden können. Dass es sich nicht nur um einen bloßen Vorschlag handelt , ist auch dem übrigen Wortlaut des Abschnitts zu entnehmen („The RACH transmissions are controlled [...] as outlined in figure 11.2.2.1.“ vgl. Anlage K 9).

ff) Für die übrigen *Access Service Classes* wird die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal nach dem Standard so wie Merkmal 2d (ii) es vorsieht in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt. Denn für die ASC#1-7 bestimmt sich die Zugriffsentscheidung danach, ob der aus N über die Beziehung $P(N) = 2^{-(n-1)}$ ermittelte Persistenzwert - ggf. skaliert mit dem Parameter $s_i$ - größer oder gleich der Zufallszahl R ist. Das Klagepatent lässt dabei offen, ob in die Zugriffsschwellwertauswertung neben den nach Merkmal 2 c) übermittelten Zugriffsschwellwertbits weitere Parameter wie der Skalenfaktor $s_i$ einfließen (vgl. insoweit bereits

Kammer, Urteil vom 27.02.2009, Az.: 7 O 94/08, juris, bei I. 2. b) zum Stammpatent, insoweit in InstGE 11, 9 nicht veröffentlicht).

## II.
## Einwendungsfreiheit der geltend gemachten Ansprüche

Den geltend gemachten Ansprüchen stehen keine Einwendung entgegen. Die Beklagten sind nicht zur Nutzung des Klagepatents berechtigt (1.) und können den Ansprüchen der Klägerin nicht den dolo-agit-Einwand entgegenhalten (2.).

### 1.
### Keine Nutzungsberechtigung

Den Beklagten steht weder aufgrund der ETSI-FRAND-Erklärung der Robert Bosch GmbH noch aufgrund der entsprechenden Erklärung der Klägerin eine Nutzungsberechtigung am Klagepatent zu.
Selbst wenn man davon ausginge, dass die ETSI-FRAND-Erklärung der Robert Bosch GmbH dem vorliegend geltend gemachten Schutzrecht aufgrund seiner Eigenschaft als Teilanmeldung aus dem von Bosch übertragenen Stammpatent anhaften würde, obwohl die Klägerin selbst die vorliegende Erfindung zum Patent angemeldet hat und daraufhin anders als in den bisher von den durch die Kammer zu entscheidenden Fällen nicht derivative sondern originäre Inhaber des Klagepatents geworden ist, können sich die Beklagten nicht auf eine positive Nutzungsberechtigung am Klagepatent berufen.

a) Die Beklagten behaupten nicht, dass es zwischen den Parteien zu einem ausdrücklich mit der Klägerin abgeschlossenen Lizenzvertrag gekommen wäre. Vielmehr geht die Argumentation der Beklagten dahin, ein entsprechendes Nutzungsrecht stehe ihnen aufgrund der ETSI-FRAND-Erklärung der Robert Bosch GmbH bzw. der entsprechenden Erklärung der Klägerin (Anlage B 37) zu. Nach französischem Recht, welches auf die Beurteilung der zugrundeliegenden Rechtsfrage anwendbar sei, sei ein sukzessionsfestes Nutzungsrecht entstanden.
b) Soweit die Klägerin eine eigene FRAND-Erklärung abgegeben hat, unterliegt diese nicht dem französischen Recht, weil die Klägerin kein Mitglied des ETSI ist und Ziffer 6 der Erklärung (Anlage B 37) die Anwendung deutschen Rechts festlegt.

c) Soweit die Beklagten an der durch die Robert Bosch GmbH abgegebenen FRAND-Erklärung anknüpfen, geht die Argumentation der Beklagten nach Auffassung der Kammer deshalb fehl, weil auf den zu beurteilenden Sachverhalt kein französisches sondern deutsches Sachrecht anwendbar ist. Insoweit hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsauffassung auch für die vorliegende Konstellation im Ergebnis fest (vgl. Kammerbeschluss vom 23.10.2009, Az.: 7 O 125/09, II. 1 c) bb) bei juris = InstGE 11, 215 ff. sowie Kammerbeschluss vom 18.12.2009, Az.: 7 O 182/08), weshalb es nicht darauf ankommt, ob die Rechtsausführungen der Beklagten zum französischen Recht zutreffend sind. Nach dem anwendbaren deutschen Recht können sich die Beklagten weder auf eine ihnen eingeräumte positive Nutzungsberechtigung noch auf ein Verbotsverzicht berufen.

aa) Französisches Recht findet im Zusammenhang mit der durch die Robert Bosch GmbH abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung bereits nach dem Schutzlandprinzip keine Anwendung.

(1) Selbst wenn mit den Beklagten die von Art. 12 der ETSI IPR Policy angeordnete Rechtswahl zugunsten des französischen Rechts sich auf die FRAND-Verpflichtungserklärungen der ETSI-Mitglieder erstrecken sollte und in den als Anlagen B 41, dort Annex B, und B 42 vorgelegten ETSI-Formblättern zur Abgabe von FRAND-Verpflichtungserklärungen die Anwendbarkeit französischen Rechts auf die IPR Licencing Declaration ausdrücklich festgelegt sein sollte, führte dies nicht dazu, dass auch auf die von der bloßen Verpflichtungserklärung zu unterscheidende Einräumung des Nutzungsrechts am Schutzrecht französisches Recht anwendbar wäre (zutreffend differenzierend: Maaßen, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, zugl. Diss. Freiburg 2005, S. 269 f. Rn. 623 f.). Die Argumentation der Beklagten überzeugt nicht, die in der ETSI IPR Policy aus kartellrechtlichen Gründen umgesetzten Vorgaben könnten nur dann verwirklicht werden, wenn einheitlich französisches Recht zur Anwendung käme.

(2) Es ist zum einen anerkannt, dass die Frage, ob und inwieweit ein Schutzrecht Schutz erlangt und inwieweit es durch Lizenzierung verwertet werden kann, nach dem Territorialitätsprinzip zu beantworten ist, wohingegen zum anderen der schuld-

rechtliche Lizenzvertrag dem Vertragsstatut unterfällt (vgl. Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 225 m.w.N.; Stöbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 27 Rn. 11). Unabhängig davon, ob man die dem deutschen Recht eigentümliche Unterscheidung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft in diesem Zusammenhang für unerheblich hält (so Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 225) oder ob man die Verfügung über das Schutzrecht durch Lizenzierung als selbständiges Rechtsgeschäft vom schuldrechtlichen Geschäft unterscheidet und hierfür das anwendbare Recht gesondert bestimmt, lässt sich die Frage, welcher Rechtsordnung die Einräumung eines Nutzungsrechts an einem Immaterialgüterrecht nach Auffassung der Kammer allein nach dem Schutzlandstatut beantworten (so im Grundsatz auch BGH, Urteil vom 16.06.1994 - I ZR 24/92 -; GRUR 1994, 798 - *Folgerecht bei Auslandsbezug*; OLG Karlsruhe, GRUR Int. 1987, 788 - *Offendspinnmaschine*; Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl. 2006, § 15 Rdnr. 225; Fezer/Koos, in: Staudinger, EGBGB/IPR Internationales Wirtschaftsrecht, Neubearb. 2010 Rn. 927 und 989; Basedow/Metzger, Festschrift Boguslavskij, 2004, S. 153, 161 f.), wohingegen eine akzessorische Anknüpfung des Verfügungsgeschäfts an das Vertragsstatut ausscheidet (vgl. zum Meinungsstand: Fezer/Koos, aaO, Rn. 927 f.). Denn das für den jeweiligen Benennungsstaat erteilte Patent ist insoweit in seiner rechtlichen Natur durch das Rechtssystem des Schutzlands bestimmt. Aus diesem Grund muss auch eine privatautonome Rechtswahlvereinbarung insoweit ausscheiden.
Damit unterliegt die Beurteilung der Nutzungsberechtigung und auch die Frage, wie die Nutzungsberechtigung zu qualifizieren ist (schuldrechtlich, dinglich oder quasidinglich, so auch Fezer/Koos, aaO, Rn. 927), vorliegend dem deutschen Recht.

(3) Auch wenn man das auf die Einräumung der Lizenz anwendbare Recht nach dem Vertragsstatut gem. Art. 27 und Art. 28 EGBGB bestimmt, führt dies zu keinem anderen Ergebnis, weil auch danach kein französisches Recht anwendbar ist (vgl. Kammerbeschluss vom 23.10.2009, Az.: 7 O 125/09, II. 1 c) bb) bei juris = InstGE 11, 215 ff. sowie Kammerbeschluss vom 18.12.2009, Az.: 7 O 182/08).

(4) Bei Anwendung deutschen Sachrechts liegt indes unabhängig von der Einordnung der einfachen Lizenz als dingliches Recht, rein obligatorische Vereinbarung oder verdinglichte Obligation (so: McGuire, Die Lizenz, zugl. Habil. Osnabrück 2009/2010,

vorgesehen zur Veröffentlichung in Ius Privatum Bd. 101, Mohr Siebeck 2010) eine Nutzungsberechtigung der Beklagten nicht vor.

(i) Qualifiziert man die einfache Lizenz als dinglich, so käme eine Nutzungsberechtigung der Beklagten allenfalls dann in Betracht, wenn man in der Abgabe der FRAND-Erklärung des ETSI-Mitglieds und Entgegennahme der Erklärung durch die Standardisierungsorganisation bereits einen Vertrag zugunsten lizenzwilliger Dritter erblicken würde (hiergegen mit überzeugenden Argumenten Maaßen, aaO, Rn. 757 ff.).

Vom dinglichen Charakter auch der einfachen Lizenz geht nicht nur das Oberlandesgericht Karlsruhe in der Entscheidung *Offenend-Spinnmaschinen* aus, wenn es von einem „*mit Drittwirkung ausgestattete[n] Nutzungsrecht*“ spricht, sondern auch der Bundesgerichtshof. Zwar nahm der Bundesgerichtshof noch in der Entscheidung *Verankerungsteil* vom 23.03.1982 (KZR 5/81 - BGHZ 83, 251) an, die an einem Patent erteilte einfache Nutzungserlaubnis sei im Regelfall schuldrechtlicher Natur, allerdings hält die Kammer diese - vom Kartellsenat getroffene - Auffassung für überholt. Mit Urteil vom 26.03.2009 (I ZR 153/06 - GRUR 2009, 946 - *Reifen Progressiv*) hat der I. Senat des Bundesgerichtshofs zum Urheberrecht entschieden, dass das einfache Nutzungsrecht ebenso wie das ausschließliche keinen schuldrechtlichen sondern dinglichen Charakter hat. Diese Auffassung überzeugt nach Auffassung der Kammer auch für das Patentrecht. Denn auch durch Gewährung einer einfachen Lizenz begibt der Patentinhaber als Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts sich eines Teils der ihm durch Hoheitsakt zugesprochenen Befugnis, ausschließlich von der erfinderischen Lehre Gebrauch zu machen. Die Erteilung der Lizenz hat nicht nur den Inhalt, dass der Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer auf die Geltendmachung seines Verbotsrechts verzichtet. Vielmehr wird durch die Lizenzerteilung bereits die Entstehung von Verletzungsansprüchen ausgeschlossen, sodass der Lizenznehmer rechtmäßig benutzt (so zutreffend: Kraßer, PatentR, 6. Aufl. 2009, § 40 V, S. 930). Dass der Patentrechtsinhaber nicht nur eine bloße einfache Nutzungsbefugnis einräumt, sondern die Einräumung der Lizenz inhaltsändernd und daher verfügend wirkt, zeigt aus Sicht der Kammer gerade die Sukzessionsfestigkeit der einfachen Lizenz nach § 15 Abs. 2 PatG.

Geht man vom verfügenden Charakter der Lizenz aus, wäre jedoch die Einräumung einer Lizenz im Wege des Vertrages zugunsten Dritter nicht möglich, weil das deutsche Recht keinen dinglichen Vertrag zugunsten Dritter kennt, da die §§ 328 ff. BGB weder unmittelbar noch analog auf dingliche Verträge anwendbar sind (vgl. Palandt/*Grüneberg*, a.a.O., vor § 328 Rn. 9; RG, Urteil vom 27.04.1907 - V 434/06 - RGZ 66, 97; BGH, Urteil vom 08.07.1993 - IX ZR 222/92 - BGHZ 123, 178).

Eine Umgehung dieses Problems über die Konstruktion des Versprechensempfängers als Vertreter ohne Vertretungsmacht (so Palandt/*Grüneberg*, a.a.O., vor § 328 Rdnr. 9; MüKo/*Gottwald*, BGB, 5. Aufl. 2007, § 328 Rdnr. 6) hält die Kammer jedenfalls vorliegend nicht für möglich. Denn der oft als Typenzwang bezeichnete zwingende und ausschließliche Charakter der Sachenrechte schließt den unmittelbaren dinglichen Rechtserwerb eines unbeteiligten Dritten grundsätzlich aus (vgl. MüKo/*Gottwald*, a.a.O., § 328 Rdnr. 203a). Das deutsche Sachenrecht will eine Schwebe des dinglichen Rechtserwerbs (bis zur Genehmigung) und die damit verbundene Unsicherheit hinsichtlich des Rechtserwerbs vermeiden. Dies kommt auch im sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz (vgl. dazu MüKo/*Gaier*, BGB, 5. Aufl. 2009, 3. Buch, Einl. Rn. 20; Benkard/*Melullis*, PatG, 10. Aufl. 2006, § 6 Rn. 27 m.w.N.) zum Ausdruck. Dem widerspricht es, wenn man die eben aus jenem Grund abgelehnte Übertragung der Regeln des Vertrags zugunsten Dritter auf dingliche Verfügungen durch ein Konstrukt wie das des Vertreters ohne Vertretungsmacht auch hinsichtlich eines zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht hinreichend bestimmbaren Rechtserwerbers ausweitet.

(ii) Auch wenn man indes den dinglichen Charakter der einfachen Lizenz verneinen und sie als rein obligatorisch oder als verdingliche Obligation begreifen wollte, können sich die Beklagten gegen über der Klägerin nicht auf eine Nutzungsberechtigung berufen. Denn bei zutreffender Auslegung der FRAND-Erklärung ist diese allenfalls auf den Abschluss eines Vorvertrages zugunsten Dritter gerichtet (vgl. Maaßen, aaO, Rn. 762 ff.). Dieser Vorvertrag wiederum wäre indes nach dem aufgrund des Schutzlandprinzips allein maßgeblichen (vgl. Fezer/Koos, aaO Rn. 989) § 15 Abs. 2 PatG nicht sukzessionsfest.

bb) Soweit durch die FRAND-Erklärung der Robert Bosch GmbH statt eines positiven Nutzungsrechts jedenfalls eine negative Lizenz in Form eines Verbotsverzichts eingeräumt worden sein sollte, wäre diese aufgrund des auch insoweit anzuwendenden

deutschen Rechts jedenfalls ebenso wenig sukzessionsfest (vgl. insoweit Kammerurteil v. 27.02.2009, Az.: 7 O 94/08, = InstGE 11, 9 ff.; Fezer/Koos, aaO, Rn. 989). Daher kann auch hier offen bleiben, ob die FRAND-Erklärung der Robert Bosch GmbH für das Klagepatent als Teilanmeldung des übertragenen Stammpatents überhaupt rechtlich bedeutsam ist.
Die von der Klägerin selbst abgegebene FRAND-Erklärung schließt eine solche Wirkung hingegen bereits in Ziffer 6 aus.

d) Schließlich kann die Kammer auch der Argumentation der Beklagten keine Überzeugungskraft abgewinnen, die Anwendung des französischen Rechts ergebe sich aus dem internationalen Gesellschaftsprivatrecht. Selbst wenn die innere Verfassung der ETSI nach Art. 37 S. 1 Nr. 2 EGBGB gesellschaftsrechtlich zu qualifizieren sein sollte und das Gesellschaftsstatut zur Anwendung französischen Rechts führte, wie das Privatgutachten der Beklagten ausführt (Anlage B 114 Rn. 27 ff.), folgt hieraus nichts für das Verhältnis zwischen Patentinhaber und nutzendem Dritten.

**2.**

**Kein Dolo-agit-Einwand**

a) Der Durchsetzung des Patents können die Beklagten auch nicht den dolo-agit-Einwand entgegenhalten, weil ihnen ein Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zustünde.
Aus Sicht der Kammer sind die Voraussetzungen eines kartellrechtlichen Lizenzanspruchs nicht dargetan, insbesondere die auch auf den vorliegenden Fall anwendbaren Kriterien, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung *Orange-Book-Standard* (Urteil v. 06.05.2009 - KZR 39/06 = GRUR 2009, 694) aufgestellt hat, nicht erfüllt, weshalb die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch durchsetzen kann.
Soweit die Beklagten argumentieren, die in der Entscheidung Orange-Book-Standard aufgestellten Kriterien seien vorliegend nicht anwendbar, da sich die Entscheidung auf einen de-facto-Standard in dem Sinne bezogen habe, dass sich eine Technologie kraft ihrer Überlegenheit am Markt in einem solchen Maße durchgesetzt habe, dass marktfähige Produkte nur noch unter Nutzung derselben hergestellt und abgesetzt werden können, wobei diese Situation mit dem in Rede stehenden Standardisierungsprozess nicht vergleichbar sei, verfängt diese Argumentation aus Sicht

der Kammer nicht. Insoweit ist eine Suspendierung des aus dem Ausschließlichkeitsrecht fließenden Unterlassungsanspruchs auch dann, wenn das Patent für einen durch mehrere Marktteilnehmer geschaffenen Standard essentiell ist, nur dann nach § 242 BGB gerechtfertigt, wenn derjenige, der die erfinderische Lehre benutzt, ab der Aufnahme der Benutzungshandlung dem Gebot von Treu und Glauben in der Weise genügt, wie sie vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard konkretisiert werden. Denn für den Marktteilnehmer, der standardgemäße Produkte am Markt anbietet, ist der Umstand, dass die Produkte dem Standard entsprechen müssen, nicht nur eine Last, sondern umgekehrt bringt die Standardisierung auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen nicht standardgemäßen Alternativtechnologien mit sich: Derjenige, der standardgemäße Produkte herstellt, hat gerade durch die Existenz des Standards bereits eine günstigere Position, um seine Produkte absetzen zu können, und profitiert insofern von der Standardisierung beispielsweise durch Kompatibilität und Interoperabilität der Produkte und leichteren Marktzutritt (so auch im Grundsatz Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626, 627 = Anlage B 51). Daher erscheint es sachgerecht, dass er dann, wenn er diesen Vorteil nutzt, und dabei von der erfinderischen Lehre eines Dritten Gebrauch macht, ihm den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nur entgegenhalten kann, wenn der Dritte ihm die Einräumung einer Lizenz verweigert hat, obwohl der Benutzer der patentgemäßen Lehre seinerseits ab Aufnahme der Benutzungshandlung alles getan hat, um sich seinerseits dem Gebot von Treu und Glauben entsprechend zu verhalten. Hierzu ist erforderlich, dass der Benutzer der patentgemäßen Lehre selbst diejenigen Anforderungen erfüllt, die das Kartellrecht dem Inhaber eines standardessentiellen Patents abverlangt: Er muss sich so verhalten, als hätte der Patentinhaber ihm Lizenz zu FRAND-Bedingungen erteilt ,und alle Vorkehrungen dafür treffen, dass es allein am Patentinhaber liegt, sich kartellrechtskonform zu verhalten. Streitet der Benutzer der erfinderischen Lehre indes in erster Linie die Benutzungshandlung ab und ist allenfalls hilfsweise bereit, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen und zu erfüllen, ist ihm der dolo-agit-Einwand verwehrt. Der bloße Umstand, dass der Patentinhaber ein standardessentielles Schutzrecht besitzt, kann nicht zur Folge haben, dass er an der Durchsetzung des aus dem Schutzrecht fließenden Unterlassungsanspruchs gehindert ist. Denn hierin offenbart sich allein der Monopolcharakter des technischen Schutzrechts. An der Durchsetzung ist der Inhaber aus kartellrechtlichen Gründen erst dann gehindert, wenn er eine Marktmacht

geltend macht, die ihre Grundlage nicht im Ausschließlichkeitsrecht selbst findet sondern allein in externen Umständen, hier dem Standardisierungsprozess, begründet ist. Um diesen nicht im Ausschließlichkeitsrecht selbst begründeten Marktvorteil zu kompensieren, ist der Patentinhaber gehalten, lizenzwilligen Dritten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzuräumen und kann sein Ausschließlichkeitsrecht folglich dann nicht durchsetzen, wenn er sich diesem Schritt verweigert.

aa) Zwar kann der aus einem Patent in Anspruch genommene grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den Einwand entgegenhalten, der Patentinhaber behindere ihn mit der Weigerung, einen Lizenzvertrag abzuschließen, unbillig in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder diskriminiere ihn gegenüber anderen Unternehmen und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stellung (BGH aaO Rn. 2 ff.).
Treuwidriges Handeln und ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung liegen indes nur vor, wenn der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne des Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden hält. Zudem muss der Lizenzsucher, der den Gegenstand des Patents bereits nutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenziertes Gegenstandes knüpft, insbesondere die Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen (BGH aaO Rn. 29). Zahlt der Lizenzsucher nicht unmittelbar an den Patentinhaber, muss er die Lizenzgebühren nach § 372 S. 1 BGB unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegen (BGH aaO Rn. 36).

bb) Vorliegend fehlt es bei Zugrundelegung dieser Kriterien jedenfalls an der Zahlung oder Hinterlegung der Lizenzgebühren unter Verzicht auf die Rücknahme. Zwar hat die Beklagte zu 1 der Klägerin das aus Anlage B 55 ersichtliche Lizenzvertragsangebot unterbreitet, jedoch weder die Gebühren an die Klägerin bezahlt noch einen entsprechenden Betrag unter Verzicht auf die Rücknahme i.S.v. § 372 S. 1 BGB hinterlegt. Den Voraussetzungen des § 372 S. 1 BGB genügt die Einzahlung eines Betrages von € 35.000.000,-- auf ein Treuhandkonto bei der Nordea Bank Finland (Anlagen 66-68) nicht. Das der Einzahlung zugrunde liegende Escrow Agreement stellt

auch bereits deshalb kein der Hinterlegung vergleichbares Erfüllungssurrogat dar, weil die einbezahlte Summe nach Klausel 5.2 (iv) (Anlage 66) und Amendment 5.2. (iv) (Anlage 67) spätestens nach dem 01.04.2013 wieder an die Beklagte zu 1 zurückbezahlt wird und auch Klausel 7 ein Kündigungsrecht der Beklagten zu 1 mit 30-tägier Frist vorsieht, sodass der Betrag nach diesem Datum nicht mehr mit Sicherheit zur Verfügung steht.

b) Soweit die Beklagten zudem einwenden, die Klägerin missbrauche die patentrechtlichen Rahmenbedingungen durch systematische Teilanmeldungen, und in diesem Zusammenhang auf die Vorgehensweise der Klägerin in Nichtigkeitsverfahren verweisen, wird weder eine Rechtsgrundlage angeführt, aus der sich ergeben würde, dass im Wege der Teilanmeldung erlangte Schutzrechte nicht gerichtlich durchsetzbar wären, noch ist eine solche sonst ersichtlich.

2. Auch den geltend gemachten Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüchen können die Beklagten keinen grundsätzlich möglichen (vgl. BGH GRUR 20004, 966 - Standard-Spundfass) kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz entgegenhalten. Denn der Klägerin stand wie festgestellt ein durchsetzbarer Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu, weil sie entgegen § 9 PatG die patentierte Erfindung in der Vergangenheit benutzt haben.

3. Soweit die Beklagten einwenden, die Klägerin gehe vorliegend aus einem „Hinterhaltspatent“ vor und sei deshalb an der Durchsetzung des Patents gehindert, verweist die Kammer ebenso auf das Kammerurteil vom 27.02.2009 (Az.: 7 O 94/08, bei III.1., veröffentlicht bei juris) wie hinsichtlich des auch vorliegend nicht durchgreifenden Einwands, die Geltendmachung der Patentansprüche sei insgesamt unverhältnismäßig (aaO, bei III.2.c).

## III.
## Rechtsfolgen

Die festgestellte unmittelbare Patentverletzung rechtfertigt die gestellten Anträge weitgehend.

1. Die Beklagten sind der Klägerin zur Unterlassung nach § 139 Abs. 1 PatG verpflichtet. Das rechtswidrige Angebot der angegriffenen Ausführungsform in der Vergangenheit begründet die erforderliche Wiederholungsgefahr für die Zukunft.

2. Da die Beklagten zur Unterlassung verurteilt werden, sind ihnen gemäß § 890 ZPO auf Antrag der Klägerin die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.

3. Durch Urteil ist festzustellen, dass die Beklagten für die begangenen Benutzungshandlungen in der Zeit vom 03.11.2007 bis 17.04.2010 zur Zahlung einer angemessen Entschädigung und für die Zeit ab dem 18.04.2010 zum Schadensersatz verpflichtet sind.

a) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von angemessener Entschädigung und Schadensersatz nicht beziffern. Da aber die Beklagten die Benutzung der Erfindung und die Patentverletzung in Abrede stellen, hat die Klägerin ein rechtliches Interesse daran, auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

b) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagten handelten schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffene Ausführungsform verletzt wird. Die Beklagten haften aufgrund des gemeinschaftlichen Vertriebs im Bundesgebiet als Gesamtschuldner (§ 840 Abs. 1 BGB).
Der Entschädigungsanspruch folgt aus § 33 Abs. 1 PatG.

4. Die Beklagten sind der Klägerin aus der Verletzung des Klagepatents auch zur Rechnungslegung verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB.

Die Klägerin kann ihre Ersatzansprüche nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Rechnungslegung fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten naturgemäß unbekannt sind, die Beklagten hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Aufwand Rechnung legen können, sind die Beklagten zur Rechnungslegung verpflichtet. Diese Verpflichtung hat sich auch auf den Gewinn der Beklagten für den Zeitraum der Schadensersatzverpflichtung und die zur Berechnung des Schadens erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden. Hierbei sind auch die entsprechenden Belege vorzulegen (OLG Karlsruhe InstGE 11, 15, 24 - *SMD-Widerstand*).

Lediglich soweit die Klägerin mit dem Antrag I.2.a) für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes (01.09.2008) Angaben zu den Einkaufspreisen fordert und hiermit die aus § 140b PatG n.F. folgende Auskunft begehrt, war der Antrag abzuweisen. Das bis dahin geltende Recht sah in § 140b PatG a.F. eine Verpflichtung, die Einkaufspreise mitteilen zu müssen, nicht vor, weshalb der Gesetzgeber bei Umsetzung des Art. 8 der Enforcement-Richtlinie entsprechenden Anpassungsbedarf sah (vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 29 und S. 39).

Soweit *Kühnen* indes die von den Beklagten zu eigen gemachte Auffassung vertritt (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. 2010, Rn. 679), ebenso seien erst seit dem 01.09.2008 Angaben zu den Verkaufsstellen zu machen, kann sich die Kamer dieser Auffassung nicht anschließen. Weder hat der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung diesbezüglich eine Regelungslücke im bisher geltenden deutschen Recht identifiziert (vgl. BT-Drs. 16/5048 a.a.O), noch ist eine solche sonst ersichtlich. Vielmehr konnten die Angaben zu den Verkaufsstellen auch nach § 140b PatG a.F., §§ 242, 259 BGB schon gefordert werden. Entsprechend formuliert auch der Gesetzgeber, dass eine inhaltliche Änderung allein mit Blick auf die geschuldeten Angaben zu den Einkaufspreisen beabsichtigt war und im übrigen allein „weitere Anpassungen an den Wortlaut der Richtlinie“ erfolgen „die aber keine inhaltliche Änderung zur Folge haben“. Soweit daher nach § 140b Abs. 3 Ziffer 1 PatG n.F. nunmehr Angaben zu den Verkaufsstellen gemacht werden müssen, wurde lediglich dem Wortlaut des Art. 8 der Enforcement-Richtlinie Rech-

nung getragen, wonach sich die Auskünfte nach Absatz 1 des Art. 8 „über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen“ gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. a auch auf die „Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren“ erstrecken. Eine inhaltliche Änderung des Auskunftsanspruch im Vergleich zum alten Recht ist damit indes nicht erfolgt.

5. Der Beklagten sind aufgrund der unmittelbaren Verletzung des Klagepatents - weitgehend dem Antrag der Klägerin entsprechend - zum Rückruf und zur Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus dem Vertriebsweg verpflichtet.

a) Der Anspruch auf einen Rückruf und auf Entfernung aus den Vertriebswegen für seit dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangten Erzeugnisse ergibt sich aus § 140a Abs. 3 S. 1 PatG n.F.

b) Der klägerische Antrag zum Rückruf und zur Entfernung war jedoch darüber hinaus in zweifacher Hinsicht zu weitgehend:

aa) Einerseits war den Beklagten im Tenor keine konkrete Vorgabe hinsichtlich der von ihnen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ergreifenden Mittel zu machen, sondern es war sich an den Wortlaut des § 140a Abs. 3 PatG zu halten, der als Tenor unter Berücksichtigung der Maßstäbe nach der Entscheidung „P-Vermerk“ des Bundesgerichtshofs (BGHZ 153, 69-82) auch hinreichend bestimmt ist (vgl. Urteil der Kammer vom 23.04.2010 - 7 O 145/09 - GRUR-RR 2011, 49, 53 zum Rückruf).
Dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für die Entfernung aus den Vertriebswegen. Selbst wenn hier im Unterschied zum Rückruf der Verletzer einen Erfolg herbeiführen muss, bleibt es ihm frei, die Mittel zur Herbeiführung dieses Erfolges zu wählen (so auch Jestaedt GRUR 2009, 102, 105, a.A. Kühnen/Geschke, a.a.O. Rn. 818, die andernfalls an der Bestimmtheit zweifeln). Entsprechend finden sich auch hinsichtlich der Art und Weise der Zielerreichung weder in der Enforcement-Richtlinie (vgl. Erwägungsgrund (24) und Art. 10) noch in der Begründung des Umsetzungsgesetzes nähere Vorgaben (vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 32, 38).

bb) Andererseits war dem Gesetzeswortlaut (in Ansehung der „Vertriebswege“) folgend klarzustellen, dass Gegenstände, die sich bei privaten oder gewerblichen Endab-

nehmern befinden, vom Tenor nicht erfasst werden (vgl. hierzu Urteil der Kammer vom 23.04.2010 - 7 O 145/09 - GRUR-RR 2011, 49, 53).

6. Der Vernichtungsanspruch rechtfertigt sich aufgrund der unmittelbaren Verletzung des Klagepatents aus § 140a Abs.1 PatG. Die Geltendmachung der Ansprüche erscheint entgegen der Auffassung der Beklagten nicht als unverhältnismäßig. Insoweit ist nicht ersichtlich, dass der rechtswidrige Zustand auf andere Weise beseitigt werden könnte. Zudem erscheint nicht hinreichend nachvollziehbar geltend gemacht, dass die Beklagte zu 1 weder Eigentum noch Besitz an entsprechenden Erzeugnissen hätte.

7. Ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des Urteils im Sinne von § 140 e PatG ist aus Sicht der Kammer nicht hinreichend dargetan.

## D.
## Keine Aussetzung

1. Der Rechtsstreit ist nicht bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen den Rechtsbestand des Klagepatents beim Europäischen Patentamt erhobenen Einspruch auszusetzen. Die Entscheidung ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer übt aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, dass von einer Aussetzung abgesehen wird. Die Kammer lässt sich hierbei von folgenden Überlegungen leiten:

a) Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg einer Nichtigkeitsklage von den Beklagten glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klagepatents genügt für eine Aussetzung nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rz. 107). Diese das Interesse der

Klägerin zutreffend beschreibenden Gesichtspunkte überwiegen im vorliegenden Fall das Interesse der Beklagten an einer Aussetzung des Rechtsstreits sowie das allgemein durch § 148 ZPO geschützte Interesse an der Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen.

b) Im einzelnen:

aa) Zwischen den Parteien steht in der rechtlichen Würdigung zurecht außer Streit, dass die erfinderische Lehre durch die Dokumente GSM 138 (Anlage B9/D4) und GSM 04.60 (Anlage B9/D6) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen ist, da die Dokumente jeweils nicht sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents vorwegnehmen.

bb) Soweit die Erfindungshöhe des Klagepatents in Frage gestellt wird, vermögen die Beklagten - jedenfalls für den Nichttechniker - nicht aufzuzeigen, dass sich kein vernünftiges Argument mehr für die Erfindungshöhe finden lässt. Auch vor diesem Hintergrund sind die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklagen nicht als hochwahrscheinlich einzustufen.

(1) Aus Sicht der Kammer ist nicht ersichtlich, dass in dem Dokument GSM 138 und dem von ihm in Bezug genommenen Dokument GSM 74 ein Zugriffssystem nach der Merkmalsgruppe 2d offenbart oder auch nur nahegelegt würde. Zwar formuliert das Dokument GSM 138 in Annex 5, dass bestimmte Nutzergruppen vom Zugriff ausgeschlossen werden müssten ebenso wie es notwendig sein könne, anderen Nutzergruppen unmittelbaren Zugriff zu gewähren. Indes ist nicht ersichtlich, dass für diese hier nur im Grundsatz angesprochene Problemstellung der Lösungsweg aufgezeigt würde, dies konkret dadurch zu bewerkstelligen, dass die Entscheidung über den Zugriff auf einen gemeinsamen Kanal in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit der Mobilstationen zu bestimmten Nutzerklassen und diesen Nutzerklassen zugeordneten Zugriffsklasseinformationen gefällt wird. Soweit die Beklagten dem in GSM 138 Annex 5, 4. Abs. verwendeten Begriff der „signalling messages“ entnehmen wollen, dass es sich hierbei um klagepatentgemäße Zugriffsklasseninformationen handele (AS 675 bei Rn. 212), kann die Kammer dem nicht ohne weiteres folgen. Vielmehr scheint hiermit nur ein irgendwie geartetes, aber gerade nicht näher

klassifiziertes Signal angesprochen. Dass es sich bei dem Signal aber gerade um klagepatentgemäße Zugriffsklasseninformationen handelt, erschließt sich der Kammer aus dem Dokument nicht. Dies gilt auch für die in Abschnitt 5.2, letzer Absatz des GSM 138 Annex 5 angesprochene „special BCCH message".

(2) Soweit die Beklagten das Dokument GSM 04.60 entgegenhalten, wird hierin wie die Beklagten zutreffend ausführen nicht offenbart, dass bestimmten Mobilstationen der Zugriff auf den RACH unabhängig von einem Schwellwertverfahren gewährt wird, sondern nur, dass bestimmten Gruppen von Mobilstationen der Zugriff per se verwehrt wird. Aus Sicht der Kammer lassen sich durchaus Argumente dafür finden, die Umkehr der im GSM 04.60 offenbarten Lösung als erfinderisch zu beanspruchen. Denn nach GSM 04.60 müssen alle zugelassenen Mobilstationen dann, wenn ein PERSISTENCE_LEVEL übersendet wird, einen Vergleich mit der Zufallszahl durchführen. Es ist indes nicht aufgezeigt, dass für die Entscheidung über den Zugriff auf den RACH bestimmte Nutzerklassen gerade in Abhängigkeit ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse von dieser Prozedur ausgenommen sind und unmittelbar zugreifen dürfen.
Diese Lösungsmöglichkeit wird nach Auffassung der Kammer auch nicht durch die sub (1) referierten Überlegungen mit einer solchen Deutlichkeit nahegelegt, dass deshalb mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents auszugehen wäre.

(3) Soweit die Beklagten auf die Entgegenhaltung nach Anlage B9/D11 und eine Zusammenschau mit dem GSM 04.60 verweisen, ist hieraus aus Sicht der Kammer ebenfalls nicht ersichtlich, dass sich das Klagepatent mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit als nicht rechtsbeständig erweisen wird.
Auch aus diesem Dokument ergibt sich aus Sicht der Kammer nicht die in der erfinderischen Lehre des Klagepatents offenbarte Lehre, dass in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformationen danach differenziert wird, ob der Schwellwerttest durchzuführen ist oder nicht. Daher lässt sich Im Hinblick auf den erfinderischen Gehalt des Klagepatents jedenfalls argumentieren, dass durch das klagepatentgemäße Vorgehen die bei dem in IS 95 vorgeschlagenen Verfahren benötigten hohen Übertragungskapazitäten reduziert werden, weil sich die Übertragung mehrerer Schwellwerte erübrigt.

(4) Auch das von der Streithelferin angeführte Dokument ARIB 32 A (Anlage ROKH1/TD1) stellt aus Sicht der Kammer die Erfindungshöhe nicht in hinreichendem Maße in Zweifel als dass eine Aussetzung geboten wäre. So ist bereits Merkmal 2a nicht ausdrücklich, sondern nach dem Vortrag der Streithelferin nur implizit offenbart, zudem nicht ersichtlich, inwiefern sich in der Entgegenhaltung Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen im Sinne des Merkmals 2b wiederfinden und diese für ein Zugriffsverfahren gemäß der Merkmalsgruppe 2d Bedeutung hätten. Der insoweit pauschale Verweis auf die Einspruchsschrift nach Anlage ROKH1 genügt der Darlegungslast nicht.

cc) Dass der geltend gemachte Anspruch unzulässig erweitert wäre, weil das Merkmal der Zugriffsschwellwertauswertung in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart sei, weil nach der Offenbarung allein ein Vergleich zwischen Zugriffsschwellwert und Zufallszahl über die Freigabe auf den Kanal entscheide, und zudem Merkmal 2a des geltend gemachten Anspruchs nicht offenbart sei, soweit dort auf die Zugriffsschwellwert<u>bits</u> abgestellt werde und schließlich Merkmal 2b eine unzulässige Verallgemeinerung darstelle, veranlasst die Kammer ebenfalls nicht zur Aussetzung des Rechtsstreits, weil es jedenfalls nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die Fachbehörde bei Prüfung dieser formellen Gesichtspunkte den mangelnden Rechtsbestand des Klagepatents feststellen wird. Hierbei war zu berücksichtigen, dass diese Argumente der Beklagten zu 1 bereits im Erteilungsverfahren als Eingabe Dritter nach Art. 115 EPÜ (Anlage B0, in Anlagenband II A am Ende) berücksichtigt wurden und das Klagepatent dennoch erteilt wurde.

2. Der Rechtsstreit war auch nicht im Hinblick auf das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe (Az.: 6 U 66/09) auszusetzen, der zwischen der Robert Bosch GmbH und der Beklagten zu 1) über die Frage des Abschlusses eines Vorvertrages zwischen den dortigen Parteien geführt wird und für den hiesigen Rechtsstreit nicht vorgreiflich ist (vgl. oben bei II.1.c).

3. Von einer durch die Beklagten beantragten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften macht die Kammer in Ausübung des ihr insoweit zustehenden Ermessens (EuGH, Slg. 1984, S. 2727, Rn. 10 - *Campus Oil*; EuGH, Slg. 1987,

S. 2545, Rn. 11 - *Pretore di Saló*) keinen Gebrauch. Umstände, die die Vorlageberechtigung vorliegend zu einer Vorlagepflicht verdichten würden, vermag die Kammer nicht zu erkennen.

## E.
## Widerklage

Die Widerklage war abzuweisen, weil die Beklagten aus den angeführten Gründen (vgl. oben bei I.2.a) keinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages haben. Der hilfsweise geltend gemachte Antrag ist bereits mangels hinreichender Bestimmtheit unzulässig.
Soweit die Beklagten zudem beantragen, festzustellen, dass der als Anlage B 53 vorgelegte Auszug für dieses Verfahren relevant ist, liegt weder ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis vor noch ist eine Anspruchsgrundlage für den begehrten Ausspruch ersichtlich.

## F.
## Zulässigkeit der Nebenintervention

Die Nebenintervenientin ist gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 ZPO zuzulassen, da sowohl die im Zwischenstreit nach § 71 ZPO zu prüfenden formellen Voraussetzungen vorliegen (dazu I.), als auch in materieller Hinsicht ein rechtliches Interesse besteht, das sich nach Auffassung der Kammer alleine aus der Tatsache der erfolgten Streitverkündung rechtfertigt (dazu II.). Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch liegen demgegenüber nicht vor (dazu III.).

I. In formeller Hinsicht waren zunächst von Amts wegen bei der Zulässigkeit der Streitbeitritte die persönlichen Prozesshandlungsvoraussetzungen der Nebenintervenientin zu prüfen (vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 10.01.2006 - VIII ZB 280/05 - NJW 2006, 773) und zu bejahen.

Der Beitrittsschriftsatz enthielt sowohl die Bezeichnung der Parteien des Rechtsstreits nach § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ZPO als auch die eigentliche Erklärung des Beitritts nach § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 ZPO.
Hinsichtlich der von § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ZPO geforderten bestimmten Angabe des Interesses des Nebenintervenienten entspricht es ständiger Rechtsprechung (so schon das Reichsgericht, Urteil vom 14.06.1921 - II 576/20 - RGZ 102, 276; Urteil vom 26.04.1929 - VII 645/28 - RGZ 124, 142; BGH, Urteil vom 10.03.1994 - IX ZR 152/93 - NJW 1994, 1537; Urteil vom 16.01.1997 - I ZR 208/94 - NJW 1997, 2385), dass hierfür alleine die Angabe, es sei der Streit verkündet worden (z. B. durch die Aufnahme der Worte „Streitverkündete“ im Rubrum des Schriftsatzes) ausreicht.

Davon abzuschichten ist die umstrittene Frage, ob die durch die Streitverkündung ausgelöste und über § 74 Abs. 3 ZPO vermittelte Gefahr der Nebeninterventionswirkung des § 68 ZPO für sich alleine für die Bejahung des nach § 66 Abs. 1 ZPO geforderten und nach § 71 Abs. 1 S. 2 ZPO im Zwischenstreit glaubhaft zu machenden rechtlichen Interesses ausreicht (so Zöller/*Vollkommer*, ZPO, 28. Auflage 2010, § 66 Rdnr. 8; Musielak/*Weth*, ZPO, 7. Auflage 2009, § 74 Rdnr. 2; OLG Köln, Beschluss vom 29.11.2004 - 22 W 27/04 - OLGR Köln 2005, 219; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.05.2010 - I-2 U 37/08 - zitiert nach Juris) oder ob auch hierfür ein weitergehendes rechtliches Interesse glaubhaft zu machen ist (so z. B. Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage 2010, § 66 Rdnr. 5).

II. Die Kammer schließt sich der erstgenannten Auffassung an, so dass in materieller Hinsicht alleine die - zwischen den Parteien unstreitig erfolgte - Streitverkündung der Beklagten an die Nebenintervenientin deren rechtliches Interesse für den jeweils vollzogenen Beitritt begründet.

1. Dies ergibt sich schon aus der zu § 70 Abs. 1 Nr. 2 ZPO ergangenen und oben zitierten Entscheidung des Reichsgerichts im 102ten Band, wo es hinsichtlich der *materiellen* Prüfung des rechtlichen Interesses nach erfolgter Streitverkündung lediglich heißt:

   *„Sobald in zweiter Instanz der Einwand der Formnichtigkeit des Vertrages auftauchte, hatten beide Klägerinnen dem Intervenienten den Streit*

*verkündet und ihm für den Fall des Unterliegens den Rückgriff angedroht. Er war daher auf das Lebhafteste an dem Obsieg interessiert, denn er musste die Verwirklichung der Drohung befürchten, [...]“*

und im Übrigen nur noch die (*formelle*) Frage diskutiert wird, welche Anforderungen § 70 Abs. 1 Nr. 2 ZPO hinsichtlich der Angabe des nach § 66 Abs. 1 ZPO zu fordernden rechtlichen Interesses macht, wenn dort ausgeführt wird:

*„Fragen kann sich nur, ob er sein Interesse durch die Worte der Revisionsschrift „streitverkündeter Nebenintervenient“ im Sinne des Gesetzes „bestimmt angegeben“ hat.“*

2. Diesem zwingenden Schluss von der Angabe einer vorangegangenen Streitverkündung im Beitrittsschriftsatz als Erfüllung des formellen Kriteriums des § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ZPO auf das Vorliegen auch des materiellen Interesses nach § 71 Abs. 1 S. 2 ZPO entspricht es, dass der Bundesgerichtshof (Urteil vom 16.01.1997, a.a.O.) - nach der Feststellung, dass der Nebenintervenient sein Beitrittsinteresse durch die Bezeichnung seiner Stellung in der Rechtsmittelschrift als „Streitverkündeter“ bestimmt genug angegeben hat - nicht etwa davon unabhängig in einer zweiten Stufe auch die materielle Existenz des behaupteten rechtlichen Interesses prüft. Er hat vielmehr darüber hinausgehend sogar für den Fall, dass die Nebenintervenientin auf der Grundlage der Entscheidung des Berufungsgerichts für den von der Streitverkündenden geltend gemachten Schaden nicht einzustehen hat, dennoch gerade allein wegen der Tatsache der erfolgten Streitverkündung ein solches rechtliches Interesse am Mitwirken am Prozess weiterhin bejaht.

3. Auch in systematischer Hinsicht ist diese Ansicht konsistent:
   Während es bei einem nicht durch eine Streitverkündung ausgelösten Beitritt, bei dem die Nebeninterventionswirkung des § 68 ZPO erst ab dem Zeitpunkt des Beitritts gilt, sinnvoll ist, neben der formellen Angabe des Interesses nach § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ZPO (z. B. die Befürchtung eines Regressanspruchs) noch dessen Glaubhaftmachung nach § 71 Abs. 1 S. 2 ZPO (z. B. durch Darlegung, warum der Beitretende derartige Regressansprüche zu befürchten habe) zu verlangen, muss es dort, wo ein zunächst unbeteiligter Dritter allein durch die Tatsache der Zustel-

lung der Streitverkündungsschrift und den gemäß § 74 Abs. 3 ZPO auf den Zeitpunkt des frühestmöglichen Beitritts vorverlegten Beginn der Nebeninterventionswirkung in einen fremden Prozess hineingezogen wird, ausreichen, dass er einerseits der von § 70 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ZPO geforderten bestimmten Angabe seines Beitrittsinteresses dadurch genügt, dass er sich als „Streitverkündeter" bezeichnet und andererseits die von § 71 Abs. 1 S. 2 ZPO geforderte Glaubhaftmachung dieses Interesses (lediglich) dadurch vorgenommen werden kann, dass er die - im vorliegenden Fall unstreitig erfolgte - tatsächliche Streitverkündung darlegt und glaubhaft macht. Alles andere würde die Anforderungen aus den oben dargelegten Gründen überspannen.

III. Äußerste Grenze eines nach erfolgter Streitverkündung grundsätzlich zulässigen Beitritts ist § 242 BGB bzw. das Verbot des Rechtsmissbrauchs.
Die für einen derartigen Rechtsmissbrauch darlegungs- und beweisbelastete Klägerin hat hierfür keine Umstände vorgetragen.

## G.
## Nebenentscheidungen

### I.
### Kosten

Die Kostengrundentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1 S. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1, 100 Abs. 4 S. 1, 101 Abs. 1 ZPO
Eine gesamtschuldnerische Kostenhaftung der Beklagten nach § 100 Abs. 4 Satz 1 ZPO kommt allein hinsichtlich der Kosten in Betracht, die anteilsmäßig durch die Schadensersatzfeststellung verursacht sind (vgl. KG Berlin, Beschluss v. 26.02.2002 - 5 W 85/01, KGR Berlin 2002, 282), nicht aber hinsichtlich der die Beklagten jeweils persönlich treffenden Unterlassungs-, Rechnungslegungs-, Rückruf-, Entschädigungs- und Vernichtungspflichten. Insoweit hat die Kammer das Interesse an der Schadensersatzfeststellung mit 10 % des auf die verbliebenen Klageanträge entfallenden Teilstreitwerts geschätzt.

## II.
## Vollstreckbarkeit

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S.1 und 2 ZPO.

Der Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten ist zurückzuweisen.
Der bloße Vortrag, die Beklagten erzielten mit dem Vertreib von Mobiltelefonen nahezu ihren gesamten Umsatz und sie würden erhebliche Markteinbußen erleiden, die voraussichtlich nicht wieder gutzumachen seien, weil Wettbewerber die Marktanteile übernehmen würden, genügt nicht, um die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO darzutun, der einen selbst im Wege der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung nach § 717 Abs. 2 S. 1 ZPO nicht zu ersetzenden Schaden für den Fall der Vollstreckung voraussetzt. Die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen aus technischen Schutzrechten hat regelmäßig die Einstellung der Produktion und des Betriebs zur Folge und eröffnet daher nicht per se den Anwendungsbereich des § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO (OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, 121 - *fahrbare Betonpumpe*). Dass die gesamte wirtschaftliche Existenz der Beklagten bedroht wäre, ist nicht dargetan.
Soweit die Beklagten darauf verweisen, bei der Klägerin handele es sich um eine reine Verwertungsgesellschaft und keine produzierende Wettbewerberin der Beklagten, vermag dies aus Sicht der Kammer das im Zweifel überwiegende Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung insbesondere von Unterlassungsansprüchen (BGH NJW 1995, 197) nicht zu beseitigen.

## H.

Die nicht nachgelassenen Schriftsätze bedürfen keiner Berücksichtigung im Urteil - soweit sie nicht ohnehin bloße Rechtsausführungen beinhalten - und veranlassen die Kammer nicht zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a, 156 ZPO).

| | | |
|---|---|---|
| Voß<br>Vors. Richter am Landgericht | Rudolph<br>Vors. Richterin am Landgericht | Dr. Tochtermann<br>Richter am Landgericht |

# Beschluss

Der Streitwert wird gem. § 63 Abs. 2 S. 1, 48 GKG auf € 30.000.000,-- festgesetzt. Angesichts des Umstandes, dass die Klägerin mit der vorliegenden Klage sämtliche UMTS-fähigen Mobiltelefone angreift, die die Beklagten bundesweit vertreiben, erschien allein die Festsetzung des höchsten nach dem GKG möglichen Streitwertes (§ 39 Abs. 2 GKG) angemessen.

| | | |
|---|---|---|
| Voß<br>Vors. Richter am Landgericht | Rudolph<br>Vors. Richterin am Landgericht | Dr. Tochtermann<br>Richter am Landgericht |